
El Estado, la constitución y el constitucionalismo

PID_00258344

Clara Marsan Raventós
Marcel Mateu Vilaseca

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 6 horas





Clara Marsan Raventós

Profesora de Derecho constitucional de la UOC.



Marcel Mateu Vilaseca

Profesor de Derecho constitucional de la UOC.

Índice

Introducción.....	5
Objetivos.....	7
1. El sistema político en una sociedad.....	9
2. Concepto y evolución del Estado.....	11
2.1. El concepto de Estado	11
2.2. Los elementos constitutivos del Estado	13
2.2.1. El ordenamiento jurídico estatal	14
2.2.2. El poder soberano	14
2.2.3. El pueblo	17
2.2.4. El territorio	20
2.3. La formación y evolución del Estado	21
3. Origen y evolución del constitucionalismo.....	24
3.1. Concepto y origen del constitucionalismo	24
3.2. Los fundamentos ideológicos del constitucionalismo	25
3.2.1. Filosofía individualista	26
3.2.2. Pensamiento contractualista	27
3.2.3. El racionalismo	27
3.2.4. La concepción de la superioridad normativa de la constitución	28
3.2.5. La filosofía liberal	28
3.3. Evolución histórica del constitucionalismo	29
3.3.1. Los orígenes del constitucionalismo: Inglaterra, EE. UU. y Francia	29
3.3.2. El siglo XIX en Europa: recesión y reanudación del constitucionalismo	34
3.3.3. El siglo XX: democratización y extensión del constitucionalismo	35
4. La constitución y la justicia constitucional.....	38
4.1. Concepto, contenido y funciones de la constitución	38
4.2. Elaboración y reforma de la constitución	44
4.2.1. La elaboración de las constituciones	44
4.2.2. La reforma de las constituciones	46
4.3. Las garantías de la supremacía normativa de la constitución. Los modelos originarios y derivados de justicia constitucional	50

4.3.1.	El sistema norteamericano o modelo difuso de justicia constitucional	52
4.3.2.	El sistema europeo o modelo concentrado de justicia constitucional	53
4.3.3.	El sistema francés o modelo de control político	54
4.4.	La interpretación de la constitución y del ordenamiento jurídico conforme a la constitución	56
Resumen.....		60
Actividades.....		63
Ejercicios de autoevaluación.....		63
Solucionario.....		66
Glosario.....		67
Bibliografía.....		69

Introducción

Actualmente utilizamos el término Estado para referirnos a la forma de organización política contemporánea. Sin embargo, históricamente, el Estado solo es una de las formas políticas en las que han vivido organizadas las sociedades. Todas las sociedades conocidas han tenido una organización política o sistema político (una manera de organizarse y resolver los conflictos y los intereses colectivos), pero el Estado no ha existido siempre, y es posible que desaparezca en un futuro, como mínimo con las características que hoy lo definen. Para poner una fecha –a pesar de que el Estado no nace de golpe, sino que es fruto de un proceso evolutivo–, se suele considerar que a partir de la Paz de Westfalia (1648) el Estado actual ya está consolidado (a pesar de que no ha dejado de evolucionar). Porque, desde que surgieron las primeras organizaciones estatales (en la Europa occidental, en un proceso lento entre los siglos XV y XVI, con precedentes desde los siglos XIII y XIV), el Estado ha pasado por diferentes etapas hasta el Estado constitucional de nuestros días, y posiblemente vendrán otras. El Estado constitucional, que es diferente en cada país, se basa en dos ideas clave del constitucionalismo (la limitación del poder y el respeto a los derechos humanos), y se fundamenta en un concepto moderno de constitución, que la entiende como la norma jurídica suprema que crea la organización estatal (con una determinada estructura de los poderes públicos basada en el principio de división de poderes), que es fundamento del orden estatal (puesto que establece un sistema de valores que fundamentan y dan sentido a las actuaciones de los poderes públicos) y ordena la producción jurídica, estableciendo los criterios para que los distintos sujetos puedan producir el resto de las normas jurídicas que forman el ordenamiento jurídico estatal.

Este módulo didáctico tiene la función de servir de introducción al resto de la asignatura porque, de hecho, es una introducción a algunos de los conceptos ahora mencionados, básicos del derecho constitucional. Más en concreto, en este módulo se estudiarán los temas siguientes:

- 1) La noción de sistema político dentro del sistema social y el consentimiento como generador de legitimidad.
- 2) Los conceptos de Estado y de constitución. La evolución histórica de estos dos conceptos, las distintas formulaciones y problemas teóricos que los afectan, para comprender la complejidad del Estado constitucional de nuestros días.
- 3) El origen y la evolución del constitucionalismo como movimiento ideológico y político que desde las revoluciones liberales hasta hoy ha llevado a la elaboración de constituciones.

4) El concepto, contenido y funciones de la constitución, así como la elaboración y la reforma de los textos constitucionales.

5) La interpretación de la constitución y del ordenamiento jurídico de acuerdo con la constitución y las garantías jurisdiccionales de la supremacía normativa de la constitución, partiendo de los tres modelos históricos u originarios de justicia constitucional.

Objetivos

En los materiales didácticos de este módulo, encontraréis los contenidos y las herramientas procedimentales para lograr los objetivos siguientes:

1. Entender la noción de sistema político, que se distingue de los otros subsistemas sociales porque posee poder político, el tipo de poder que, si fuera necesario, se puede ejercer de manera coercitiva.
2. Comprender el concepto de Estado como la forma de organización de la vida política occidental desde la edad moderna hasta nuestros días, en los que se ha generalizado y ha llegado a ser la forma de organización política contemporánea.
3. Aproximarnos a los elementos constitutivos del estado: ordenamiento jurídico, poder soberano, pueblo y territorio.
4. Analizar el origen y la evolución del constitucionalismo, desde las revoluciones liberales hasta nuestros días.
5. Estudiar el fenómeno del Estado constitucional, su evolución y sus problemas más importantes, para captar las implicaciones que este concepto presenta hoy día.
6. Entender el concepto y los tipos de constitución, así como sus funciones.
7. Determinar cómo se elaboran y se reforman las constituciones, en qué consiste la superioridad normativa de los textos constitucionales, los mecanismos de garantía de esta jerarquía suprema y muy especialmente las garantías jurisdiccionales o justicia constitucional.
8. Conocer los criterios de interpretación del ordenamiento jurídico según lo establecido en la Constitución.

1. El sistema político en una sociedad

Desde Aristóteles, es tradicional considerar a la persona como un «animal político» (*zoon politikon*) que vive y se relaciona con otros individuos en la sociedad. Tal y como remarca Isidre Molas, **el sistema político existe siempre en el seno de una sociedad y en íntima relación con ella y no es un sistema completo, sino una de las partes integrantes del sistema social**. Según este autor, la vida humana en sociedad está basada en una multiplicidad de interrelaciones y lazos, que, vistos globalmente, pueden llegar a producir una impresión abigarrada de desorden; pero, por debajo de su diversidad y aparente dispersión, en la convivencia social hay regularidades, un orden. Y a lo largo de la historia, los individuos han intentado lograr un orden social a partir de la ordenación de la convivencia, de acuerdo con la voluntad de uno, de varios o de todos. Entre los polos extremos y opuestos del anarquismo (que propone la superación del sistema político estatal) y el totalitarismo (que persigue la absorción de los sistemas sociales por el sistema político), se sitúan las múltiples propuestas que ha habido históricamente para ordenar la relación entre el sistema político y el sistema social global (entre el Estado y la sociedad, de acuerdo con la terminología del pensamiento político clásico).

Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que están interrelacionados y que interactúan entre sí (y que tiene propiedades que sus elementos no poseen). Los sistemas (o subsistemas) que integran el sistema social son construcciones intelectuales y, por lo tanto, según los diferentes sociólogos (como por ejemplo Almond, Easton, Bottmore, Bunge o Parsons, entre otros) puede haber más o menos, como por ejemplo el sistema económico, de comunicación, cultural, junto con el sistema político. Para Isidre Molas, las finalidades del sistema político serían tres:

- **El mantenimiento de la existencia y el funcionamiento de la sociedad**, a pesar de la distribución desigual de los bienes, estatus y roles entre sus miembros.
- **El mantenimiento de la paz en la resolución de los conflictos derivados de la vida en común**, mediante la previsión (para intentar evitarlos) o su resolución (en el supuesto de que estallen).
- **La no subordinación de la comunidad respecto a otras sociedades**.

Para asegurar estas finalidades, el sistema político tiene que contar con un poder coercitivo (un poder de dominación, basado en el uso de la fuerza coercitiva) y una libertad de movimientos suficiente (una autonomía relativa de actuación respecto a los otros sistemas, de los cuales recibe las demandas y los apoyos). El ejercicio del poder político no consiste en el uso permanente de la

Lectura recomendada

I. Molas (2008). *Derecho constitucional* (págs. 17-22). Madrid: Tecnos.

coerción, pero cualquier poder político es necesariamente coercitivo, aunque solo lo sea como una posibilidad. La coerción es lo específico del poder político, su núcleo esencial. Por lo tanto, **el sistema político se distingue de los otros subsistemas sociales porque posee poder político, que es el tipo de poder que, si fuese necesario, se podría ejercer de manera coercitiva.**

Ahora bien, **el poder político no se basa solo en la fuerza, sino también en el consentimiento.** Para Max Weber (*Economía y Sociedad*), sin la colaboración de los que obedecen (al menos de una parte importante de ellos) el ejercicio del poder no funciona correctamente, porque este es más efectivo cuanto más fuertes son los lazos afectivos sobre los cuales se puede apoyar. No hay ningún poder solo coercitivo o solo consensual. Todos los sistemas políticos se fundamentan, poco o mucho, en un cierto grado de consentimiento, en una cierta aceptación de la autoridad. Por hábito, por creencias arraigadas, o simplemente porque se está de acuerdo, las decisiones de quienes tienen el poder suelen ser aceptadas y las personas acostumbran a cumplir los mandatos del poder sin que sea siempre necesario el uso de la fuerza. **Y la aceptación genera legitimidad.** Para González Casanova (*Teoría del estado y derecho constitucional*):

«Un poder es legítimo cuando tiene la *adhesión* de quienes lo experimentan, por el hecho de que surge de la *fuerza* que los adherentes *creen* que es de la que debe surgir; por el hecho de que se ejerce de la *forma* en que se cree que tiene que ejercerse, y por el hecho de que quiere o se dirige a unas *finalidades* que son las que la gente *cree* que son deseables para ella.»

Aun así, dado que todas las sociedades son plurales y a menudo llegar a un consenso es muy difícil (si es que es posible), hay que encontrar unos mecanismos para que aquellos que no están de acuerdo con una decisión la acaten porque aceptan su legitimidad. Y tal y como subraya Molas:

«En el sistema político moderno se ha tendido a desplazar el juicio de legitimidad, respecto de cada decisión en concreto, hacia el juicio sobre la legitimidad del procedimiento general para tomar decisiones.»

Para este autor, si el poder político se basara solo únicamente en la coerción nos encontraríamos ante un régimen de fuerza sin legitimidad. Si solo se basara en la legitimidad, sus decisiones podrían llegar a ser ineficaces y, por lo tanto, no se trataría de un verdadero poder político. **Las decisiones del poder político, que adoptan el carácter de normas jurídicas (el derecho), tienen la pretensión de ser, al mismo tiempo, eficaces y válidas; es decir, de unir aplicabilidad y legitimidad.** De aquí deriva la permanente tensión entre fuerza y derecho. Y de aquí proviene la comprensión del poder político como coerción, como fuerza cualificada por el derecho. Y así, la prueba para determinar la existencia efectiva de un sistema político es que sus mandatos sean eficaces, que produzcan efectos. Y si en la poliarquía medieval europea la fuerza se ejercía de manera dispersa, **en el sistema político moderno, en cambio, el uso de la fuerza se ha concentrado en una unidad de poder, especializada y estructurada: el Estado.**

2. Concepto y evolución del Estado

2.1. El concepto de Estado

El Estado es la forma de organización de la vida política occidental desde la edad moderna hasta nuestros días, en la que se ha generalizado y se ha convertido en la forma de organización política contemporánea.

Como hemos visto, todas las sociedades conocidas han tenido una organización política o un sistema político (una manera de organizarse y resolver los conflictos y los intereses colectivos), y el Estado solo es una de las formas políticas en las que han vivido organizadas las sociedades. El Estado no ha existido siempre, y puede que desaparezca en un futuro, al menos con las características que hoy lo definen.

Hay varios factores que apuntan a la ruptura de la forma del Estado westfaliano que estudiamos. Por un lado, tenemos los procesos de integración regionales como por ejemplo el de la Unión Europea, por medio de los cuales los estados ceden soberanía. Por otro, son numerosos los casos de organizaciones infraestatales que reivindican soberanía o autonomía para erigirse en organizaciones políticas autónomas. Finalmente, no hay que olvidar la creciente vulnerabilidad de los estados en relación con organizaciones privadas, como por ejemplo grandes empresas tecnológicas u otras multinacionales, porque pueden, con una relativa facilidad, coaccionar a estados pequeños y medianos para que tomen medidas políticas y legislativas favorables a sus intereses particulares.

Tanto en el lenguaje no técnico como en el jurídico, **acostumbramos a usar el término Estado para referirnos a tres realidades diferentes**, aunque directamente relacionadas.

En primer lugar, consideramos que el Estado es un grupo social jurídicamente organizado, formado por una comunidad estable de personas, asentada en un territorio y dotada de un poder soberano que reivindica con éxito un doble monopolio, el de la coacción física legítima y del reconocimiento del derecho.

Ejemplo

Usamos este concepto amplio de Estado cuando afirmamos, por ejemplo, que un Estado determinado está en guerra con otro o cuando sostenemos que el Estado del Chad tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo.

En segundo lugar, **también usamos la palabra Estado en un sentido más restringido, para referirnos únicamente al poder soberano, al conjunto de órganos (Gobierno, Parlamento, tribunales de justicia, etc.) que constituyen el aparato de Gobierno al que está sujeto este grupo social.**



Para el alemán Max Weber (1856-1920), el Estado es «la obra predilecta del Renacimiento».

Ejemplo

Así, empleamos este sentido más restringido de Estado cuando afirmamos que el Estado alemán graba a sus ciudadanos con unos impuestos elevados o cuando decimos que el Estado español cada vez interviene más en la planificación de la economía.

Cuando usamos este concepto restringido de Estado, ponemos de manifiesto que el aparato de Gobierno y la sociedad estatalmente organizada no constituyen una realidad unitaria y en armonía perfecta, sino que entre ellas puede haber tensiones y conflictos.

En tercer lugar, en los estados con un sistema de organización territorial con autonomía política (como el Estado español o el italiano) **podemos utilizar el término Estado en un sentido aún más restrictivo para referirnos solo a una parte del aparato de Gobierno: los órganos generales, los que ejercen sus competencias para todo el territorio del Estado**, por contraposición a los órganos autonómicos, regionales o locales (que tienen un ámbito territorial más restringido).

Ejemplo

En este sentido, podemos afirmar que la constitución española reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y fuerzas armadas, materias sobre las cuales los estatutos de autonomía no pueden asumir ninguna competencia para las comunidades autónomas.

Según destaca Carles Viver Pi-Sunyer, en esta primera acepción más amplia del término, **el Estado se diferencia de otras organizaciones o grupos sociales jurídicamente organizados por su carácter político y obligatorio, y por unos elementos específicos, constitutivos, sin los cuales no podría existir. Para Viver, el Estado es una organización política en el sentido de que, a diferencia de la inmensa mayoría de los grupos sociales, persigue unas finalidades generales e indeterminadas.** Los otros grupos poseen unas finalidades concretas y determinadas (culturales, deportivas, etc.) que permiten calificar la «naturaleza» del grupo (como organización cultural, deportiva, etc.). El Estado, en cambio, más allá de las finalidades propias que hemos visto que tenía cualquier sistema político (el mantenimiento de la existencia y el funcionamiento de la sociedad, el mantenimiento de la paz en la resolución de los conflictos derivados de la vida en común y la no subordinación de la comunidad respecto a otras sociedades), **quiere llevar a cabo una tarea genérica: organizar la vida social en los ámbitos, en la forma y con los medios que la correlación de fuerzas sociales determine en cada momento histórico.** El Estado no tiene unas finalidades concretas y predeterminadas. Esto lo demuestra el hecho de que en el transcurso del tiempo sus funciones han ido variando, sin modificar su naturaleza. Solo hay que ver el cambio experimentado sobre el Estado «abstencionista» del siglo XIX (que se limitaba a asegurar el orden público, a administrar justicia, a la defensa nacional y al mantenimiento de las relaciones exteriores) y el Estado «intervencionista» del siglo XX

Lectura recomendada

Carles Viver Pi-Sunyer (1992). *Ordenament constitucional. Constitució* (págs. 4-15). Barcelona: Vicens Vives.

(que, además de llevar a cabo las funciones anteriores, interviene en la mayor parte de la vida económica y social, actúa como planificador de la economía, como empresario, como prestamista de servicios públicos, etc.).

Como segunda característica diferencial, **el Estado es una organización obligatoria**. A diferencia de la mayoría de los grupos sociales, el hecho de **pertenecer a un Estado no depende exclusivamente de la voluntad de los asociados**. Los ciudadanos pertenecen al Estado y están sujetos a su poder de Gobierno independientemente de su voluntad. Ningún ciudadano puede decidir de manera unilateral que, por ejemplo, las leyes estatales no lo obligan. Y para dejar de pertenecer a un Estado, tienen que cumplirse una serie de requisitos establecidos en las normas dictadas por el aparato estatal.

Ahora bien, el Estado no se diferencia de los otros grupos sociales solo por su carácter obligatorio y político (por tener unas finalidades generales e indeterminadas), sino también por **las características de los elementos que hacen falta para su existencia**, que a la vez **diferencian al Estado de otros sistemas políticos que lo han precedido**.

2.2. Los elementos constitutivos del Estado

Partiendo de la noción de Estado que hemos apuntado (como grupo social jurídicamente organizado, formado por una comunidad estable de personas, asentada en un territorio y dotada de un poder soberano que reivindica con éxito un doble monopolio, el de la coacción física legítima y del reconocimiento del derecho), podemos afirmar que **el Estado se caracteriza por ejercer un tipo de poder que denominamos político, que disfruta del atributo de la soberanía, y que se canaliza de manera significativa mediante el derecho, sobre un pueblo y un territorio determinados**. De esta aproximación conceptual, se pueden extraer los llamados «elementos constitutivos» del Estado, los elementos necesarios para la existencia del Estado: **el ordenamiento jurídico, el poder soberano, el pueblo y el territorio**. Aun así, siempre que ha habido una forma política ha habido poder (es decir, dominación de unas personas sobre otras) y, en consecuencia, se tiene que haber producido este fenómeno mediante unas normas y dentro de una determinada población que habitaba un territorio. Estos cuatro factores (normas, poder, población y territorio) son elementos constitutivos de la definición de todas las formas políticas históricamente conocidas. **Lo que diferencia al Estado de otras formas de organización política anteriores son las características específicas que veremos que adoptan estos cuatro elementos en el caso del Estado**: la igualdad en un mismo territorio, la concentración en el aparato del Estado de la coacción legítima, la despersonalización del poder, su carácter soberano o el monopolio del reconocimiento del derecho en el territorio, entre otras.

2.2.1. El ordenamiento jurídico estatal

Para que haya un Estado, tiene que haber un conjunto ordenado y sistemático de normas jurídicas que se denomina ordenamiento jurídico estatal, que constituye, regula y a la vez expresa el Estado. En palabras de Viver Pi-Sunyer:

«El ordenamiento jurídico estatal constituye el Estado porque delimita los otros elementos constitutivos: determina el territorio sobre el cual se ejerce el poder estatal, precisa el grupo humano (pueblo) que está sujeto a este poder y establece el aparato de Gobierno al cual dota de un poder público soberano.»

Decimos que regula el Estado porque somete a reglamentación, por un lado, todo lo que considera necesario en relación con los particulares y sus relaciones privadas (familiares, patrimoniales, mercantiles, etc.) y, por otro lado, también regula los aspectos fundamentales que hacen referencia a los órganos o instituciones del Estado y las relaciones entre el aparato estatal y los ciudadanos (normas penales, tributarias, etc.). Finalmente, se puede afirmar que el ordenamiento jurídico no solo constituye y regula el Estado, sino que también lo expresa, en el sentido de que «el Estado generalmente actúa por medio del derecho, expresa sus decisiones por medio de normas jurídicas» (C. Viver).

Dentro del territorio estatal, todas las organizaciones (asociaciones, iglesias, partidos, sindicatos, etc.) tienen sus propias normas (su propio ordenamiento), pero **el ordenamiento estatal se diferencia de los otros por su carácter originario y soberano**. Es originario porque no deriva de ningún otro, no extrae la validez de ningún otro, y es soberano porque dentro del territorio estatal el ordenamiento del Estado es el supremo, está por encima de todos los otros y, por lo tanto, cualquier norma que contradiga lo establecido por el ordenamiento estatal será considerada ilegal.

2.2.2. El poder soberano

El poder del Estado no es un poder cualquiera sobre las personas. En la sociedad, se pueden dar muchos tipos de poder según las distintas relaciones sociales (como por ejemplo poderes económicos, de presión, de grupos o de colectivos como las familias). Ahora bien, **lo que caracteriza al poder del Estado es su supremacía y su carácter obligatorio, porque se quiere imponer por encima de cualquier otro poder social, si hace falta mediante la coacción**. Por eso es un poder que se aplica sobre todo el conjunto de individuos de una sociedad. Así pues, lo específico de la forma histórica «Estado» es la organización del poder político mediante el monopolio de la potestad de *imperium* o dominio sobre todos los miembros de la comunidad. El Estado es el poder político unificado e institucionalizado, que tiene capacidad exclusiva y excluyente para generar coerción, para hacer la ley e imponerla, atribuyendo deberes y obligaciones sin necesidad del consentimiento individual. Por lo tanto, **el poder público es el poder del que dispone el aparato de Gobierno estatal para dirigir el grupo social y mantener el orden interno, y que fundamen-**

talmente consiste en la capacidad de imponer unilateralmente deberes a los ciudadanos y en la potestad consiguiente de recurrir al uso de la fuerza para conseguir el cumplimiento de estos deberes.

Este monopolio estatal del uso legal de la fuerza tiene como consecuencia la prohibición a los particulares de hacer uso de la misma; cuando una persona quiere hacer valer un derecho frente a otra, no puede usar la fuerza directamente (salvo los casos excepcionales de la legítima defensa o el estado de necesidad), sino que tiene que recurrir a los órganos estatales competentes (como por ejemplo los tribunales de justicia o la policía) para que declaren si su pretensión es ajustada a derecho y, en caso afirmativo, la hagan valer y usen la fuerza si es necesario. **El Estado niega el uso libre de la resistencia o de la fuerza a los particulares, y establece que solo pueden ejercerla los agentes del poder público o las personas que el Estado autorice.**

El Estado ejerce el poder político del que dispone mediante potestades o poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Dado que el Estado no es una persona física, no puede ejercer «personalmente» estas funciones o potestades y **necesita unos instrumentos capaces de formar y expresar la voluntad estatal. Estos instrumentos son los órganos del Estado,** que tienen atribuciones o competencias para ejercer sobre determinadas materias parte del poder coercitivo del Estado, de acuerdo con unos procedimientos previstos y normalmente mediante actos jurídicos. Porque hay que tener presente que, **además del ejercicio de la función legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, la actividad estatal también incluye una actividad de dirección política** (señalar objetivos, priorizarlos y decidir dedicar unos medios para conseguirlos), que no se manifiesta directamente por medio de actos jurídicos, aunque algunos de sus aspectos estén regulados jurídicamente y finalmente se traduzcan en normas o actos administrativos.

El ejercicio del poder público o estatal queda reservado a una pluralidad de instituciones u órganos del Estado, cuyos titulares son personas físicas que, en tanto que efectúan una función pública, se les asignan unos regímenes especiales de actuación. Estos órganos pueden ser unipersonales (formados por una sola persona física, como un juez o el jefe del Estado) o pluripersonales (formados por más de una persona como, por ejemplo, el Gobierno, el Parlamento o un tribunal).

Para asegurar la igualdad, cada uno de los órganos del Estado (que se estudian con detalle en la asignatura Derecho constitucional), y muy especialmente **la Administración pública, tienen que ser una instancia objetiva, despersonalizada, que se relacione «por igual» con todos los individuos, que así resultarán equiparados, todos, en la categoría de ciudadanos.** A diferencia de lo que sucedía en la edad media (con pactos personales entre señores feudales y diferentes relaciones de vasallaje) y en las monarquías estamentales (diferentes privilegios que se podían pactar con compensaciones a cambio), el Estado se acabará caracterizando (sobre todo cuando llegue a ser un Estado

de derecho) por tener unos órganos despersonalizados, un poder impersonal o institucionalizado que se relaciona por igual con todos los ciudadanos. El Estado, y más claramente el Estado de derecho, no es el Gobierno de personas, sino el Gobierno de la ley por medio de la Administración.

Finalmente, **también caracteriza al poder estatal el hecho de que está dotado del atributo de la soberanía**. Jean Bodin, ya en el siglo XVI, afirmó que «soberano es el poder supremo no sometido a las leyes», que nos dice más o menos que quien es soberano hace la ley, es la fuente del derecho, es **la justificación tras el poder político** establecido, y no tiene que pedir permiso a nadie para imponer sus decisiones.

Los estados empiezan a surgir con el Renacimiento, que es el periodo en el que las monarquías consiguen culminar un doble proceso: de independencia en cuanto a los emperadores y el papado (independencia exterior) y a la vez consolidación y reafirmación de su poder unificador sobre los señores feudales, que hasta aquel momento habían sido prácticamente soberanos en sus feudos (supremacía interna). Desde entonces, más que el concepto de soberanía, lo que **ha ido evolucionando a lo largo de la historia es quién se considera titular o depositario de esta soberanía**, que actúa como fuente de legitimación del poder político existente: primero el monarca (en la monarquía absoluta, el rey era el soberano), después el rey con el Parlamento (en las denominadas monarquías constitucionales, liberales pero no democráticas, la soberanía es compartida entre el rey y el Parlamento), más tarde la nación (representada por unas élites que pese a ser una minoría de la población, se autoatribuyen la soberanía nacional) y, finalmente, el pueblo (soberanía popular). Así, en palabras de Isidre Molas, el Estado liberal se construyó sobre el deseo de acabar con la soberanía autocrática (de los reyes o de los dictadores) para atribuirla a la nación (cuya voluntad era dictada, de hecho, por la oligarquía económica y cultural), y el Estado democrático se construyó a partir de la idea de que solo el pueblo en su conjunto expresaba la voluntad de la nación y que la soberanía oligárquica, por ilustrada que fuera, era tan abominable como la soberanía monárquica. Sin embargo, tanto los liberales como los demócratas pusieron la soberanía como elemento central de referencia, ejercida por el Parlamento (como Gran Bretaña) o mediante la aprobación de una constitución (un acto de constitución de la comunidad por el que se organizaban los poderes del Estado). Hoy, **desde un punto de vista democrático, solo el pueblo puede ser el titular originario de la soberanía**, entendida como poder ilimitado de creación y justificación del Estado, aunque se pueda entender que se ejerce en un proceso constituyente o mediante un Parlamento como el británico, que puede ir haciendo leyes que actualicen el ordenamiento constitucional (y entonces se vincula siempre al presente y no al pasado).

El concepto de soberanía tiene una doble acepción, según si nos fijamos en su expresión hacia el exterior o hacia el interior. **En la dimensión o sentido externo, la soberanía significa que el poder estatal no está jurídicamente subordinado a ninguna otra comunidad política y, por lo tanto, se puede**



Jean Bodin (1529-1596) es conocido por su formulación de un concepto moderno de soberanía, recogido en su obra *Los seis libros de la República* (1576).

entender como sinónimo de independencia (jurídica) en el ámbito internacional. Aun así, la capacidad real de ejercer esta soberanía (que, teóricamente, es un poder absoluto y está por encima de todo) ha llegado a ser bastante relativa, especialmente en los estados pequeños y medianos, no solo porque estamos en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, sino especialmente por la dominación de hecho (económica, tecnológica, comunicativa y cultural) de unos pocos (grandes potencias estatales o poderes no estatales) sobre el resto. **En la dimensión «interna», soberanía se puede entender como poder jurídicamente supremo sobre todos los otros poderes que existan en el interior de sus fronteras y, por lo tanto, jurídicamente supremo también sobre los ciudadanos**, en el sentido de que antes hemos comentado que es un poder que se considera **con la capacidad de imponer unilateralmente deberes a todos los ciudadanos y con la potestad exclusiva y excluyente de recurrir al uso de la fuerza para conseguir el cumplimiento de estos deberes**.

En síntesis, el segundo elemento necesario para que haya un Estado es que tenga un poder soberano, que quiere decir que dentro del territorio estatal no hay ningún poder, ni interior ni exterior, que pueda imponer contra la voluntad del Estado ningún deber ni ninguna obligación que vincule jurídicamente a los ciudadanos.

2.2.3. El pueblo

El tercer elemento indispensable para que haya un Estado son las personas, porque el Estado es una forma organizativa del sistema político de una sociedad humana. **El pueblo (*demos*, en griego) está formado por todos los ciudadanos**, es decir, **por todos aquellos que tienen un vínculo jurídico con el Estado denominado *nacionalidad* o *ciudadanía***. Por lo tanto, **no se tiene que confundir el pueblo con la población** (que es un concepto que incluye a un conjunto más amplio de personas), **porque dentro del territorio de un Estado pueden residir personas que no sean ciudadanos** de aquella comunidad política constituida (los extranjeros y los apátridas), y porque una parte de este pueblo puede residir en otros estados.

El Estado ejerce su soberanía sobre todas las personas que están en su territorio, pero el régimen jurídico es distinto según si estas personas tienen o no la condición de ciudadano: solo los ciudadanos tienen todos los derechos y deberes; los extranjeros pueden ver cómo algunos derechos les son restringidos, especialmente los de más contenido político, como el derecho de sufragio o el acceso a algunos cargos públicos.

Este concepto de pueblo, **delimitado jurídicamente, a menudo se usa como sinónimo de nación**, como comunidad política jurídicamente organizada en un Estado. **Sin embargo**, además de este concepto jurídico de nación,

hay como mínimo dos otras grandes concepciones de nación, según si se adopta una perspectiva social objetiva o una perspectiva política subjetiva.

La concepción objetiva entiende la nación como una comunidad de personas que comparten unas características específicas que la hacen diferente de las otras comunidades, como por ejemplo una lengua, una cultura (en un sentido amplio que incluye folclore, tradiciones, fiestas, gastronomía, etc.), la historia, la etnia, la religión, el derecho o la estructura económica, entre otras. No todas las naciones deben tener rasgos específicos en todos estos campos, ni todas estas características tienen la misma importancia a la hora de singularizar a una nación concreta. Y algunos de estos elementos comunes, que son factores de agregación, pueden ir cambiando con el tiempo, a pesar de que en los inicios de esta conceptualización, que es de raíz principalmente germánica, se concebía la nación como un hecho «natural» y algo indisponible para las personas. Estas naciones así definidas a menudo se denominan *naciones naturales*, *sociales* o *nacionalidades* (para remarcar que son comunidades con identidad nacional, pero sin Estado propio). En este sentido, la comunidad de personas que forman la ciudadanía de un Estado puede ser uninacional o plurinacional, aunque el Estado en cuestión no reconozca jurídicamente o incluso niegue su carácter plurinacional. Y si hay estados formados por varias naciones, también existen casos en los cuales la población de una nación natural o social está repartida entre diferentes estados, como por ejemplo la nación kurda o la alemana, que, en la época contemporánea, no ha coincidido nunca con la nación política (tened presente la existencia de Austria y que la lengua alemana es hablada por una gran parte de la población de Suiza, en Luxemburgo, Liechtenstein, Chequia e incluso en otros estados vecinos de Alemania). En una nación social o nacionalidad puede surgir un sentimiento de identidad colectiva singular, de conciencia de formar una comunidad con unas características objetivas compartidas, y aparecer también una voluntad de autogobernarse, que al límite la puede llevar a querer constituirse en un Estado.

Frente a esta concepción que remarca el elemento objetivo, hay otra concepción que pone en primer plano el elemento subjetivo, la voluntad de un conjunto de personas de convertirse en comunidad política, de tal manera que aunque no tuviesen los rasgos característicos de nacionalidad o nación «natural», si hubiera voluntad comunitaria, políticamente habría una nación. Para esta concepción política-subjetiva, la nación sería un grupo humano constituido por personas de características sociales nacionales diferentes o por una o más de una nación natural, cuyos miembros comparten mayoritariamente la voluntad de formar una comunidad política diferenciada, y concretan esta voluntad de autogobierno en un Estado independiente, un Estado federado o algún que otro tipo de entidad política autónoma dentro de un Estado unitario o compuesto. Sería el caso, por ejemplo, de Suiza, Bélgica, Estados Uni-

dos o Canadá, donde la pluralidad nacional se mantiene en el seno de una comunidad política, con más o menos discusión y con diferentes formas de organizar su pluralismo.

Sin embargo, independientemente de la concepción sobre la nación de la que se parta, se puede coincidir en la constatación de que **la mayor parte de los estados actuales se han construido y han definido sus fronteras a partir de guerras, pactos matrimoniales entre monarquías o por reparticiones arbitrarias sobre un mapa, independientemente de la voluntad de la población** que habitaba en aquel territorio.

Si el diseño y el reparto de los estados surgidos de la descolonización que hicieron las potencias colonizadoras hubieran intentado que las fronteras fuesen más fieles a las realidades nacionales, la existencia de sociedades precoloniales organizadas con sus normas y costumbres, con la cohesión de pueblos por motivos étnicos, culturales o religiosos (entre otros), seguramente el altísimo nivel de conflictos y tensiones étnicas que a menudo han desembocado en guerras sangrientas y grandes crisis humanitarias habría podido reducirse de manera significativa.

Y, a partir de esta constatación histórica, con mucha frecuencia se ha considerado el Estado como una realidad que preexiste lógicamente al pueblo (el Estado posee un territorio y el pueblo está formado por las personas que viven en el mismo). Sin embargo, si revertimos esta lógica y formulamos la relación de una manera más conforme con el principio democrático, podemos afirmar que es el pueblo quien posee un Estado (y no el Estado quien posee un pueblo) y, por lo tanto, el Estado es, o tendría que ser, la organización política de las personas asentadas en un territorio que se constituyen en comunidad política, que se deriva (o se tendría que derivar) de la voluntad de sus integrantes. Aun así, el aparato estatal a menudo ha sido dominado por una de las naciones sociales que integran el Estado (generalmente, la que tenía una población más numerosa) y gracias al control del aparato de Gobierno esta nación se ha hecho hegemónica, favoreciendo sus rasgos nacionales o reprimiendo las principales características de las otras naciones, aplicando por ejemplo políticas de absorción lingüísticas y culturales hacia los alófonos (los que hablan una lengua diferente). Así, a menudo en un largo proceso histórico, el aparato estatal, controlado por una de las naciones que convivían en un mismo territorio, ha intentado uniformizar su sociedad para llegar a crear una nacionalidad homogénea, en la que se estableciera finalmente una identificación entre nación social y comunidad política estatal-nacional. El Estado habría creado la nación, para llegar a ser un Estado-nación. En algunos estados, este proceso habría tenido bastante éxito (por ejemplo en el Estado francés), y en otros no se habría acabado de completar (por ejemplo, en el Estado español).

Simultáneamente a estos procesos, a lo largo de los siglos XIX y XX algunas nacionalidades europeas (como por ejemplo los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania a finales del siglo XX) pugnaron para convertirse en nacio-

nes en sentido político y formar estados propios, de acuerdo inicialmente con el principio de las nacionalidades, que después se regulará como derecho a la autodeterminación nacional.

En el siglo XXI, este es un proceso que continúa abierto y crea un intenso debate entre juristas y politólogos. Por un lado, tenemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, recogido en el art. 1.2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que todos los estados que forman parte de la misma han aceptado y tienen que respetar, y el artículo 1.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1976), que otorga a todos los pueblos el derecho a la autodeterminación para que estos puedan determinar libremente su estatuto político. Todavía no se ha definido de manera exacta y definitiva qué hay que entender por pueblo o nación a efectos de quién tiene este derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero hasta ahora se ha reconocido principalmente a las colonias, pero no exclusivamente, como, por ejemplo, en el caso de Kosovo, en el cual en una importante resolución, la Corte Internacional de Justicia reconoció que su independencia era válida a partir del principio de autodeterminación proclamado en la Carta de la ONU y que su declaración unilateral de independencia no violaba ninguna norma jurídica internacional. Desde entonces, el debate sobre la aplicación del derecho a la autodeterminación permanece abierto, dentro del cual hay posicionamientos claramente opuestos entre los diferentes estados miembros de la ONU.

Todos estos procesos ponen de manifiesto que hoy día la identidad nacional es (o continúa siendo) uno de los factores que tienen una mayor fuerza política, en la medida en que es capaz de generar vínculos de una intensa solidaridad, que a menudo se imponen a los religiosos, ideológicos o de clase.

Sin embargo, independientemente de si el Estado es o no plurinacional, y de qué forma organice su pluralismo, **lo que caracteriza al pueblo como elemento constitutivo del Estado es este vínculo jurídico de la nacionalidad, que iguala a todos los ciudadanos en un mismo territorio en una igualdad básica de derechos y deberes.** Una igualdad básica, porque en los estados compuestos (federales o con autonomía política) puede haber algunas diferencias en materia de derechos y deberes.

2.2.4. El territorio

Para poder hablar de Estado, hace falta un cuarto y último elemento. Es necesario que el ordenamiento jurídico establezca el ámbito espacial en el que ejercerá el poder estatal y excluya la intervención de cualquier otro poder soberano. Por lo tanto, **el territorio es el ámbito espacial de competencias del Estado** o, en palabras de Kelsen, «el ámbito de vigencia de un orden jurídico» donde ejerce su soberanía. Esto no impide que un Estado (o un grupo de estados) pueda ceder –en una decisión soberana– el ejercicio de algunas competencias estatales a alguna otra entidad, como por ejemplo la Unión Europea.

En algunos casos el territorio estatal está fijado en la constitución, pero en otros casos no es así. El territorio español, por ejemplo, actualmente no está establecido en la Constitución de 1978, sino que está delimitado en los tratados internacionales y ha variado mucho respecto a lo que establecía la Constitución de 1812, que especificaba los territorios dentro de la península ibérica,



El austriaco Hans Kelsen (1881-1973) es uno de los juristas más importantes del siglo XX.

los que estaban en la América septentrional, la América meridional y en Asia, porque partía de la idea de que la nación española «era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» (art. 1).

El concepto jurídico de territorio es más amplio que el concepto físico, en el sentido de que, además de la **tierra firme** y eventuales islas (en el caso español el territorio peninsular, las islas Baleares y las Canarias, otros islotes pequeños, y las ciudades de Ceuta y Melilla), comprende el **mar territorial** (la zona adyacente a la costa hasta 12 millas) y la columna de agua hasta el subsuelo marino, y también **el espacio aéreo** sobre la tierra firme y el mar territorial.

No se pueden considerar partes del territorio «la plataforma continental» (el subsuelo situado fuera del mar territorial hasta una profundidad de 200 metros) o la zona económica sobre las cuales los estados tienen normalmente derechos de explotación de recursos naturales y de pesca (la columna de agua de 200 millas de distancia del límite del mar territorial). Por otro lado, las embajadas en estados extranjeros y los barcos y aviones cuando están en aguas o en espacio aéreo internacional no se pueden considerar técnicamente parte del territorio del Estado, pero en los mismos tiene vigencia el ordenamiento jurídico de este Estado, y se les aplican los principios de inmunidad y de extraterritorialidad.

2.3. La formación y evolución del Estado

Como se ha apuntado, el poder político establecido en una sociedad no siempre ha adoptado la forma estatal. Las ciudades griegas, el Imperio Romano o el feudalismo medieval son consideradas formas políticas preestatales.

La forma política que denominamos Estado surge entre los siglos XV y XVI en la Europa occidental, a partir de la desintegración del sistema político feudal (la poliarquía medieval) y la formación de las primeras monarquías absolutas.

En efecto, **el mundo feudal estaba formado por una multitud dispersa y autónoma de pequeñas o medianas organizaciones políticas**. Los vínculos del vasallaje entre los señores configuraban un sistema de fidelidades mediante el cual se daba protección a todo aquel que era sometido a la respectiva jurisdicción. El derecho estaba formado por privilegios o concesiones que los señores daban a los vasallos. Toda la estructura política culminaba en un rey o príncipe que era un *primus inter pares* (el primero entre iguales) respecto al resto. La Iglesia romana ejercía un gran poder unificador, ideológica, política y jurídicamente, teniendo en cuenta su autoridad sobre los señores y príncipes.

Los eclesiásticos que se dedicaron al estudio del derecho hicieron una importante tarea en la preparación de las bases del Estado y el sistema representativo. Dado que la autoridad la tenía Dios, pero «en la tierra» la ejercía el papa, había que encontrar fórmulas que justificaran cómo el poder traspasaba del primero al segundo y cómo el segundo podía ser un poder absoluto e irreprochable si, en el fondo, se trataba de un humano que se podía equivocar. De los eclesiásticos medievales, pues, surgió la idea de que el papa cuando estaba reunido en Concilio era cuando verdaderamente ejercía poder, lo que proporcionó los fundamentos para la representación parlamentaria actual.

En la baja edad media, a partir del siglo XII, se dan una serie de cambios que serán determinantes para el posterior desarrollo del Estado. Aumentan el comercio y la economía monetaria, al compás del surgimiento de las ciudades, donde viven artesanos y comerciantes o burgueses. Paralelamente, los reyes incrementan la jerarquía respecto a los señores feudales y a su alrededor se empieza a crear un nuevo derecho que es concebido como liberador de los vínculos feudales y territoriales.

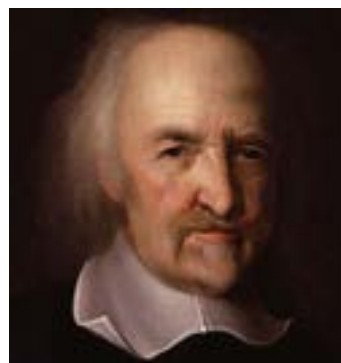
En el siglo XV, al inicio de la edad moderna¹, se desarrollan los primeros estados modernos como estructuras de gobierno centralizadas al amparo de un monarca. Se desarrolla un mundo urbano más centrado en torno a la burguesía y el comercio. Habrá un proceso de secularización que supondrá que la religión se legitimará por sí misma y que el Estado como organización no esté subordinado a la Iglesia. **El Estado absoluto será la primera forma de estructura estatal. Le llamamos absoluto porque persigue la concentración de todo el poder político, pasando de la poliarquía medieval a la monarquía del mundo moderno.** El rey es una institución emergente, que rompe los antiguos vínculos feudales (las relaciones de vasallaje) y se empieza a relacionar directamente con sus súbditos. El rey será así el titular de la soberanía, y en torno a su poder se edificará el Estado. Este poder no necesita la religión, sino que, como teorizó **Maquiavelo** (1469-1527), se justifica por sí mismo, tiene sus propias reglas de funcionamiento y se **valora el éxito en la capacidad de acceder y mantenerse en el poder.**

(1) El mundo de la edad moderna está marcado por el invento de la imprenta en 1453 o el descubrimiento de América en 1492. Posteriormente, en el siglo XVI, la revolución copernicana pone al hombre y no a Dios como centro del universo, y permite el desarrollo del humanismo (Erasmus de Róterdam).



Maquiavelo, el florentino Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, autor de *El Príncipe* (1513), fue diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor.

El Estado necesita un *Príncipe* que imponga un orden, que sepa usar la fuerza, pero también buscar el consentimiento de los súbditos. Algo más tarde, el francés **Jean Bodin** (1529-1596), **al definir la soberanía, puso de manifiesto el carácter hegemónico del poder estatal**, como poder común a las distintas familias o sectores sociales. Por su parte, el inglés **Hobbes pondrá de manifiesto el carácter irresistible del poder estatal, su capacidad de *imperium* para generar un orden para la convivencia.** Este autor, en el contexto de las revoluciones del siglo XVII para establecer un nuevo orden en Inglaterra, defiende en su *Leviatán* (1651) la creación de un Estado fuerte para superar la guerra civil, a partir de un contrato de sumisión de los súbditos.



Thomas Hobbes (1588-1679). Su libro *Leviatán* es considerado el primer tratado moderno de filosofía política.

Esta primera formulación del Estado como Estado absoluto se hace realidad históricamente en lo que se ha denominado *Estado-nación* –Inglaterra, Francia, por ejemplo–, donde las leyes van teniendo progresivamente un carácter más territorial que personal, creándose al mismo tiempo un ámbito de comercio cada vez más libre dentro de sus fronteras.

A partir del siglo XVII, las concepciones contractualistas y jusnaturalistas, entre otras que estudiaremos en el apartado siguiente, pusieron las bases del constitucionalismo. Las revoluciones liberales o burguesas trajeron como consecuencia el establecimiento de un Estado liberal, limitado, caracterizado por la existencia de una constitución (fruto de un poder constituyente), por un reforzamiento del Parlamento como órgano que frenará el poder del rey, por la separación y control de los poderes estatales, y por la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esta es la apuesta del constitucionalismo de la tradición liberal democrática, que comentamos a continuación.

3. Origen y evolución del constitucionalismo

Empezaremos por el concepto y origen del constitucionalismo, y expondremos después sus fundamentos ideológicos y la evolución histórica (las revoluciones liberales de Inglaterra, Estados Unidos de América y Francia, el siglo XIX en Europa y la democratización y la extensión del constitucionalismo en el siglo XX). Partimos de la idea de que para comprender mejor lo que es una constitución y el derecho constitucional, es conveniente disponer de unos fundamentos mínimos del proceso que conocemos como constitucionalismo, porque el concepto actual de constitución es heredero de aquel proceso y resultado de un periodo histórico concreto. En este sentido, Francisco Tomás y Valiente (1996) afirmó que:

«No hay dogmática sin historia. O no la tendría que haber, porque los conceptos y las instituciones no nacen en un vacío puro e intemporal, sino en lugar y fechas conocidos y como consecuencia de procesos históricos de los que arrastran quizá una carga invisible, pero condicionante.»

3.1. Concepto y origen del constitucionalismo

El constitucionalismo es un **movimiento ideológico, político y jurídico que propugna una forma de organización política basada en la limitación del poder arbitrario** –y, por eso, se opuso en sus orígenes al absolutismo y se vinculó con el liberalismo– **para conseguir la garantía de la libertad y los derechos individuales**. La libertad y la igualdad aparecen como unos grandes valores que hay que desarrollar mediante la aprobación de constituciones. Para entender el constitucionalismo y las ideas de fondo que defiende, es determinante recordar el famoso artículo XVI de la *Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano* (1789), aprobada durante la Revolución Francesa: «Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, no tiene constitución».

Los dos grandes instrumentos para llevar a cabo la limitación del poder y la garantía de la libertad individual serán el principio de la separación de poderes y el reconocimiento de unos derechos y libertades a los ciudadanos.

El Estado constitucional nace como Estado liberal, y **el derecho es la técnica mediante la cual se quiere conseguir la limitación y el control del poder arbitrario del monarca**. Para el primer constitucionalismo, solo hay estado constitucional cuando responde a los principios liberales (limitación y separación de los poderes, garantía de la libertad individual frente a la intervención estatal, y otros que también serán determinantes, como por ejemplo el Gobierno representativo y la soberanía nacional, en especial en Francia). El constitucionalismo se desarrolla en una teoría, pero también en una práctica

Lectura recomendada

F. Tomás y Valiente (1996). «Independencia judicial y garantía de los derechos fundamentales». En: *Constitución: Escritos de introducción histórica*. Madrid: Marcial Pons.



Portada de la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* (1789).

consistente en la ordenación racional de la comunidad política mediante la aprobación de constituciones, que generalmente son textos escritos con pretensiones de estabilidad que expresan las condiciones para ejercer el poder político. A pesar de que no siempre un Estado constitucional tiene una constitución totalmente escrita (como es el caso del Reino Unido), y teniendo en cuenta que las primeras constituciones fueron un conjunto de textos fundamentales y no un solo texto, podemos definir el Estado constitucional como aquel en el que la constitución contiene las normas fundamentales, constitutivas, de los poderes del Estado y de su organización, para que se garanticen la libertad y los derechos individuales.

El constitucionalismo es un movimiento garantista, dado que mediante técnicas e instrumentos jurídicos, inicialmente, quiere hacer posible la limitación del poder del monarca para así trasladar parte de este poder a los ciudadanos (burguesía ilustrada) y asegurar que estos sean libres e iguales. Posteriormente, el constitucionalismo sumará los principios democráticos a estos valores liberales de inicio.

El constitucionalismo, si bien tiene unos orígenes históricos vinculados al pensamiento y los valores del liberalismo y, por lo tanto, se desarrolla al compás de las revoluciones liberales, no se expresa del mismo modo en todas partes. El constitucionalismo americano logra desde el principio una aplicación más jurídica, una vez aprobada la Constitución federal de 1787, que se considera la «ley suprema del país», y consagra así la superioridad normativa de la constitución por encima del resto de las leyes. En Europa, en cambio, cuesta más que la constitución llegue a ser un texto plenamente jurídico, que vincule los poderes públicos y a los ciudadanos. A pesar de las primeras experiencias revolucionarias, **la fuerza de los elementos monárquicos** (en especial, durante la primera mitad del siglo XIX) **dificultó el desarrollo del concepto normativo de constitución**, de modo que se dieron cartas otorgadas (autolimitaciones voluntarias de los monarcas en la etapa posnapoleónica), o se dieron pactos entre el rey y el Parlamento. De este modo, **en la Europa del siglo XIX la constitución fue más un texto político que jurídico**, y el Parlamento y su producto normativo, la Ley, la norma más importante. La constitución será más bien una ley más, eso sí, importante por su función política, y para limitar los poderes del rey, pero no será plenamente aplicable a los ciudadanos hasta bien entrado el siglo XX.

3.2. Los fundamentos ideológicos del constitucionalismo

El movimiento constitucionalista se fundamenta en una filosofía individualista, en el pensamiento contractualista, el racionalismo, la concepción de la superioridad normativa de la constitución y los postulados liberales.

3.2.1. Filosofía individualista

La filosofía individualista defiende una concepción del hombre libre, racional, plenamente capaz para gestionar su vida y propiedades. **Frente a los privilegios del antiguo régimen, defiende unos derechos naturales** (según la filosofía jusnaturalista) de todos los hombres libres, anteriores a cualquier organización social y política, una libertad natural previa al poder político que este solo puede reconocer y garantizar. **Las declaraciones de derechos expresan el planteamiento mencionado.** Situadas, en un principio, fuera de los textos constitucionales, **son concebidas como limitaciones del poder, y compromisos de los gobernantes.**

Así, en Inglaterra, la *Petition of Right* (1628), el *Habeas corpus Act* (1679) o *Bill of Rights* (1689), o en las antiguas colonias norteamericanas, la *Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia* (1776) y la de *Independencia* (1776). En Europa, hay que destacar la *Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano* (1789), el mismo año del estallido de la Revolución Francesa. La Constitución francesa de 1791 no contenía ninguna declaración de derechos y remitía a la de 1789. La Constitución de Estados Unidos de América (EE. UU.) tampoco contenía ninguna declaración de derechos cuando se aprobó en 1787, pero la incorporó a partir de 1789 con las diez primeras enmiendas.

Si bien en un primer momento las declaraciones de derechos se situaron fuera de las constituciones, pronto se pusieron en relación y a la larga se incorporó a todos los textos constitucionales una parte, llamada dogmática, dedicada a reconocer una lista de derechos fundamentales a las personas.

De este modo, las constituciones se dividen en dos grandes partes, la dogmática y la orgánica, en la que se regula la organización de los poderes del Estado. Hay que decir también que **la parte orgánica se estructuró a partir del principio de la separación, equilibrio y control de los poderes, entendiendo que *el poder limita el poder* y esta es la mejor garantía de la libertad de los ciudadanos.**

Con la evolución del Estado constitucional, **las declaraciones de derechos reconocerán derechos de libertad** (de expresión, de movimientos, de propiedad), **derechos políticos** (asociación, manifestación, sufragio universal, participación) y **derechos económicos, sociales y culturales** (educación, sindicación, huelga, seguridad social). Sin embargo, en todo caso, **la idea de constitución ha quedado vinculada al reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales y a la organización del poder público según el principio de la separación de poderes.**

3.2.2. Pensamiento contractualista

Desde este punto de vista, **la constitución es concebida como un pacto o un contrato del que surgen la sociedad y el mismo Estado**. El jusnaturalismo, en su versión racionalista, fue una filosofía muy influyente durante los siglos XVII y XVIII, que defendió la existencia de unas leyes naturales previas a las humanas que la razón podía deducir. En términos políticos, se entendía que los miembros de una sociedad pactaban y consentían el establecimiento de un Gobierno limitado y representativo, que tenía que respetar las condiciones del pacto suscrito y no ir más allá. **Autores importantes que expresan esta ideología, a pesar de que cada uno con sus propios matices, son Locke, Rousseau o Kant.**

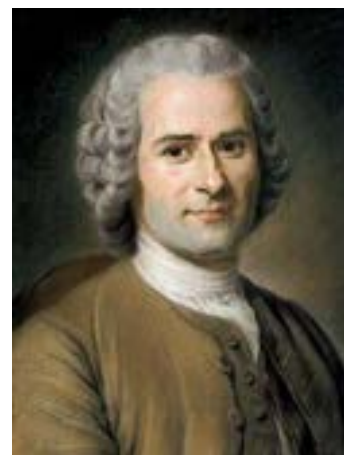
Se parte de que hay un «estado de naturaleza» que tiene que ser respetado en la configuración de la sociedad y del Estado. **La constitución es el documento que expresa el pacto fundacional** de la sociedad organizada y del Estado. Inicialmente, por lo tanto, el constitucionalismo en su versión liberal sostiene la rígida separación entre Estado y sociedad, el primero como ámbito del poder que hay que limitar y el segundo como espacio de la libertad. Una separación que se irá desvaneciendo con los años, a medida que aumente el intervencionismo estatal. **Esta idea de constitución como norma fundacional, como pacto social que crea el Estado, quedó reforzada porque se llevó a cabo históricamente en América:** primero en las colonias, en el momento en el que se convirtieron en Estado con la aprobación de sus constituciones y, posteriormente, con la Constitución de 1787 que creó Estados Unidos de América.

3.2.3. El racionalismo

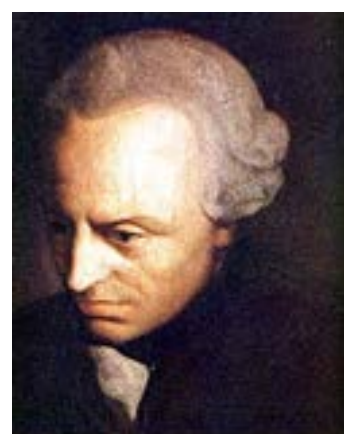
El liberalismo se desarrolla paralelamente a las ideas racionalistas, y de manera específica se puede observar en la Ilustración del «siglo de las luces» (siglo XVIII) y en su gran obra: la *Enciclopedia*. Frente al dogmatismo, la intolerancia medieval de la fe religiosa y el absolutismo, **la Ilustración propugna la libertad de pensamiento y de expresión, convencidos de que la razón conducía de manera natural a la libertad y a la igualdad**, objetivos del constitucionalismo. Se parte de la posibilidad de captar el mundo mediante la razón, porque según los ilustrados la verdad se conoce mediante la discusión libre y racional, la razón es la máxima fuente para conocer la realidad de la vida. El racionalismo se manifestará en una defensa del derecho escrito, producto de la razón, en contra de las costumbres tradicionales y, por lo tanto, en la fuerza ordenadora de la razón humana. De este modo, se harán codificaciones del derecho y se redactarán textos constitucionales, delimitados en un único documento. **La constitución sería, por lo tanto, un código político escrito que crearía el poder y racionalizaría el orden político y, de aquí, deriva otra idea de fondo del constitucionalismo: el intento de racionalización del orden político mediante la regulación en derecho del poder público.**



John Locke (1632-1704) fue un filósofo empirista inglés. Su obra *Ensayo sobre el Gobierno civil* es considerada el manifiesto del liberalismo moderno.



Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) publicó *El contrato social* en 1762. Su famoso *Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres* (1755) es concebido como un diálogo abierto con la obra de Thomas Hobbes.



Immanuel Kant (1724-1804) es el máximo exponente de la Ilustración y pensador extraordinariamente influyente en los siglos XIX y XX.

3.2.4. La concepción de la superioridad normativa de la constitución

La idea de que hay una ley fundamental, primaria, de la cual derivan el resto de las normas, y que, por lo tanto, no todas las leyes son iguales en importancia, es otro fundamento del constitucionalismo. Desde antiguo, la idea de constitución se ha asociado a una norma superior y fundamental de la comunidad política. Así, en Roma tenemos las *constitutio* del emperador, en la edad media las *lex terrae*, o en el antiguo régimen las *leyes fundamentales* del Reino. Sin embargo, donde se ve más claro este carácter es en la tradición inglesa de la *common law*, el derecho común del reino formado por reglas no escritas, principios y precedentes judiciales que se consideran superiores a las leyes del Parlamento. En el siglo XVII, el juez Coke defendió la posibilidad de que los jueces pudieran anular las leyes contrarias a la *common law*.



Sir Edward Coke (1552-1634) fue juez y parlamentario, y un defensor del Estado de derecho ante el absolutismo real.

El principio inglés de la soberanía parlamentaria dificultó este planteamiento, pero, en cambio, en EE. UU. se trasladó como criterio para valorar la idoneidad de las leyes parlamentarias, hasta el punto de que, desde el principio, se consideró que daba argumentos para rebelarse contra la ley (como el principio *no taxes without representation*, que legitimó la revuelta contra la metrópoli y justificó todo el proceso de independencia posterior). En este sentido, la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América hace referencia al hecho de que el rey inglés no ha respetado los derechos naturales inalienables de sus súbditos, y que hay un derecho natural anterior a las decisiones humanas que no se tiene que ignorar.

Más tarde, se consagró la idea de la constitución como norma suprema, superior a las otras leyes. Sobre esta base, los jueces norteamericanos formalizaron el control de constitucionalidad de las leyes a partir de principios del siglo XIX. Como hemos visto, esta concepción de la superioridad normativa de la constitución costó más de introducir en Europa, y el control de constitucionalidad de las leyes no se instauró hasta bien entrado el siglo XX. En todo caso, la concepción de la constitución como norma suprema deriva también de la idea de *poder constituyente*, superior y generador del resto de los poderes, que son constituidos, es decir, creados en el texto constitucional.

3.2.5. La filosofía liberal

Ya hemos visto que el constitucionalismo nace como un movimiento profundamente vinculado al liberalismo, a la idea de limitación del poder y a la garantía de la libertad individual. Sin embargo, el constitucionalismo evolucionó hacia la democracia especialmente a lo largo de los siglos XIX y XX. Liberalismo y democracia son filosofías políticas diferentes, a pesar de que se pueden dar juntas. El liberalismo persigue la limitación del poder, la democracia se preocupa del origen y las condiciones de ejercicio de este poder. Los estados occidentales han evolucionado y se han situado en lo que se ha denominado democracias liberales. Las estructuras del Estado liberal se

han democratizado y la soberanía nacional o popular se concibe como legitimación del mismo Estado. Las revoluciones liberales cambiaron el concepto de soberanía, porque este pasó del rey a la nación (vinculada al sufragio restringido o censatario, y a una comprensión de la nación como ente que tiene una vida propia con independencia de las personas que la forman); posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se fueron incorporando los principios democráticos, con el reconocimiento del sufragio universal, el derecho de asociación política y una ampliación de la base social de legitimación del Estado.

Constitucionalismo y democracia no siempre han ido unidos, pero en los dos últimos siglos ha habido un proceso de incorporación de la democracia a las estructuras del Estado constitucional. En todo caso, la constitución responde a un acto de autodeterminación voluntaria de una comunidad que se expresa de manera soberana.

3.3. Evolución histórica del constitucionalismo

Siguiendo la síntesis de los profesores Fossas y Pérez Francesch, se pueden marcar tres etapas en la evolución histórica del constitucionalismo:

- La fase inicial del constitucionalismo, cuyos principios básicos aparecen en Inglaterra (en un largo proceso de transformación de sus estructuras políticas que culminó a finales del siglo XVII) y posteriormente triunfan en EE. UU. y en Francia, con sus revoluciones liberales de finales del siglo XVIII.
- Un periodo de recesión del constitucionalismo en Europa a principios del siglo XIX (Restauración), que se retomará en los años treinta de este siglo y se consolidará de manera progresiva.
- Una tercera etapa, en el siglo XX, de democratización y extensión del constitucionalismo, en tres oleadas, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del comunismo (derrumbe del muro de Berlín).

Lectura recomendada

Enric Fossas Espadaler;
Joan Lluís Pérez Francesch
(1994). «Evolució històrica
del constitucionalisme». En:
Lliçons de dret constitucional
(1.ª ed., págs. 29-40). Barcelo-
na: Enciclopèdia Catalana.

3.3.1. Los orígenes del constitucionalismo: Inglaterra, EE. UU. y Francia

En este primer momento, que coincide con el triunfo de los principios políticos liberales primero en Inglaterra y después en Estados Unidos de América y Francia, el constitucionalismo inicia el proceso de limitación del poder político hasta entonces asociado al absolutismo.

La constitución deviene un instrumento mediante el cual la burguesía consigue participar en la dirección del Estado. La soberanía aparece asociada a la nación, a pesar de que en la práctica dominará una concepción de compartir el poder entre el rey y el Parlamento. Los derechos que se garantizan son propios del Estado liberal y se articulan en torno a la libertad, la seguridad y la propiedad. La constitución no es un texto democrático porque domina una concepción del poder en manos de un sector reducido del pueblo, la burguesía, y en general aquellas personas que tienen un determinado nivel de rentas o ingresos (sufragio censatario).

Las características anteriores se muestran en **los tres grandes modelos de revolución liberal**, a los cuales podemos asociar unas características específicas del constitucionalismo y que marcarán unas líneas de evolución.

Inglaterra

En Inglaterra **triunfan una gran parte de los principios del constitucionalismo liberal a lo largo del siglo XVII**. Se trata de una adecuación lenta y evolutiva de las instituciones tradicionales. **La continuidad institucional se produce mediante el principio de soberanía parlamentaria**. El triunfo del Parlamento en la «Gloriosa Revolución» de 1688 se refleja en dos documentos constitucionales: *Bill of Rights* (1689), declaración de derechos frente al rey, y el *Act of Settlement* (1701), que establece las nuevas condiciones del gobierno real y la independencia de los jueces. En Inglaterra **se desarrolla un constitucionalismo basado en el equilibrio de poderes**, que quiere establecer un gobierno moderado, **en el cual las instituciones se limiten entre ellas**: el rey, la *common law*, las leyes, las costumbres, el Gabinete, el Parlamento, los jueces, etc.

El sistema político inglés **se configura a partir de finales del siglo XVII como un régimen parlamentario**: el Gabinete se separa progresivamente del rey y de su exclusiva confianza. Los ministros necesitarán la confianza de la Cámara de los Comunes y se establecerá la convención de que los miembros del Gobierno tienen que ser también miembros del Parlamento; el Gobierno surgirá de la mayoría parlamentaria, y será responsable políticamente ante el Parlamento; el primer ministro irá adquiriendo relieve como líder de la mayoría parlamentaria y como jefe del Gobierno. En el sistema político inglés se desarrollará un bipartidismo, influido por el sistema electoral mayoritario, entre conservadores (*tories*) y liberales (*whigs*).

El reconocimiento de los derechos de las personas por los jueces es otro objetivo del constitucionalismo anglosajón, de forma que se puede hablar de dos momentos en este proceso: el reconocimiento judicial en el caso concreto (*freedom of speech, freedom of meeting*) y las grandes declaraciones en tex-

Lectura recomendada

R. Jiménez Asensio (2003). *El constitucionalismo. Proceso de formación y fundamentos del Derecho Constitucional* (2.ª ed., págs. 36-45). Madrid: Marcial Pons.

tos legales parlamentarios. Al mismo tiempo, se consagra el principio de la sumisión del poder al derecho mediante el *rule of law*, es decir, la sujeción a la ley ordinaria del país, administrada por los tribunales ordinarios.

Uno de los hechos más singulares del constitucionalismo inglés y posteriormente británico es que **no tiene un texto constitucional escrito y codificado**. La constitución está formada por un conjunto de textos de diferentes tipos, desde el siglo XIII hasta nuestros días. Por eso se dice que hay una «**constitución no escrita**», pero lo que se quiere decir es que **no está escrita en un único texto**. Las fuentes del derecho constitucional británico son: **leyes parlamentarias con carácter constitucional** (*statute law*), entre las cuales podemos destacar la *Carta Magna* (1215), la *Petition of Right* (1628), el *Habeas corpus Amendment Act* (1679), la *Bill of Rights* (1689), el *Act of Settlement* (1701) o las *Parliament Acts* (1911 y 1949), entre otras; el **derecho judicial** (*case law*) derivado de las decisiones judiciales más importantes, tanto del derecho consuetudinario (*common law*) como del derecho legislativo, y las **convenciones** (*conventional rules*), es decir, las prácticas que se consideran vinculantes a la vida política (así se han ido desarrollando instituciones como el primer ministro, el Gabinete o la responsabilidad política de este ante el Parlamento).

Por otro lado, **la constitución inglesa es una constitución flexible**, es decir, que las leyes que forman parte de la misma se pueden modificar sin un procedimiento especial, como si fueran las leyes ordinarias. **Las leyes constitucionales se diferencian de las otras por su contenido** (por la materia), **pero no por la jerarquía**. Por lo tanto, **no hay superioridad normativa de la constitución** ni ningún órgano que pueda controlar la constitucionalidad de las leyes. En el Reino Unido no hay una superioridad jerárquica del poder constituyente; el soberano es el pueblo por medio del poder constituido en el Parlamento. Así pues, al no haber un poder por encima del Parlamento, tampoco hay una norma por encima de las leyes del Parlamento. El constitucionalismo británico ha influenciado notablemente a otros estados constitucionales, como por ejemplo los miembros de la Commonwealth (federación de las antiguas colonias) o, en menor medida, los países escandinavos.

Estados Unidos de América

El constitucionalismo norteamericano nace con las trece colonias que se declaran independientes de la metrópoli en 1776, mediante la ***Declaración de Independencia***.

Este es un documento interesante por el planteamiento que hace: dado que el rey inglés no ha respetado los derechos naturales e inalienables de sus súbditos, en especial el de tener representantes, proclaman el derecho de constituirse en estados independientes y basados en el consentimiento de los gobernados. **Una vez obtenida la independencia, los nuevos estados se dotarán de constituciones**. Este es un hecho importante porque son las primeras muestras de constituciones escritas, sistemáticas y codificadas, aprobadas por



La firma de la *Declaración de Independencia* (cuadro de John Trumbull).

una asamblea constituyente y con un contenido liberal: una declaración de derechos y una organización de los poderes basada en el principio de separación de poderes.

Así, la **Constitución de Virginia (1776) fue la primera constitución liberal escrita de la historia**. No nos tiene que sorprender que, también en este momento, aparecen las primeras expresiones escritas sobre la existencia de un poder constituyente. En los nuevos Estados Unidos fue muy importante remarcar que hay un nuevo poder soberano que constituye un nuevo orden, y es esta visión de la relación entre poder constituyente y poder constituido (así como de constitución en relación con las leyes ordinarias), que calará en la mayor parte de los estados constitucionales del mundo. Podemos decir, pues, que el constitucionalismo norteamericano nace rompiendo esquemas tradicionales y creando un nuevo orden partiendo de principios propios, en contraste con lo que hemos visto que caracterizó el constitucionalismo inglés: la continuidad y la lenta transformación de las instituciones tradicionales.



La obra de Montesquieu *El espíritu de las leyes* (1748), que recoge la visión de este pensador liberal e ilustrado, no tuvo tanta influencia en Francia como en Estados Unidos.

La primera articulación política entre los nuevos estados norteamericanos fue la **confederación** (*Articles of Confederation*, 1777), mediante la cual conservaban su soberanía, pero delegaban algunos poderes (sistema postal, conclusión de tratados, declaración de la guerra). **Al poco tiempo se replanteó el tipo de unión** hacia vínculos más sólidos en la Convención de Filadelfia (1787), en la cual los representantes de los estados **aprobaron un proyecto de Constitución federal que**, después de ser ratificada, **entró en vigor en 1789**, año en el que George Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos.

Se trata de un texto breve, de siete artículos, relativos a la organización del poder federal y a la reforma de la constitución. **Posteriormente, por la vía de enmiendas, se incorporaron nuevos artículos referentes a la declaración de derechos** (las diez primeras enmiendas se aprobaron en 1791). La Constitución de 1789, que continúa vigente, tuvo a lo largo del siglo XIX una gran influencia en todo el mundo, y muy especialmente en América Latina.



La Convención de Filadelfia aprobó la Constitución de Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787, todavía hoy vigente, a pesar de que se han hecho múltiples reformas (enmiendas).

El sistema norteamericano consagra la **supremacía normativa de la constitución, en un texto codificado, situado por encima de todas las leyes, las federales y las de los estados miembros**. En el artículo VI, se define el texto constitucional como «la ley suprema del país». A partir de aquí, se desarrollará el **control de constitucionalidad de las leyes** como mecanismo de garantía de esta superioridad normativa, lo cual **se inició con el famoso caso *Marbury vs. Madison* (1803)**. Desde entonces, los jueces ordinarios están legitimados para juzgar la constitucionalidad de las leyes (*judicial review*).

El federalismo es un **segundo elemento característico del constitucionalismo de Estados Unidos de América**. La Constitución es producto de un **doble pacto fundacional**, entre ciudadanos pero también entre estados. Se generó, así, el Estado federal, en el que hay un reparto de competencias entre

la federación y cada Estado miembro o federado. Se trata de un modelo que hace posible la unidad dentro de la diversidad. Y que, además de la separación de poderes horizontal (entre legislativo, ejecutivo y judicial), **añade una división territorial o vertical del poder.**

El sistema presidencial es otra aportación del constitucionalismo norteamericano. Los órganos principales de la federación serán el presidente, el Congreso y el Tribunal Supremo, dentro de un diseño de separación rígida de poderes, pero a la vez guiados por los *checks and balances*, es decir, los controles y contrapesos entre estos órganos, gracias a los cuales se entiende que se garantiza la libertad de los ciudadanos. El presidente (jefe del Estado y del ejecutivo) se inspira en la figura del monarca inglés del siglo XVIII, elegido por unos compromisarios, a partir de la elección popular, que comparte con el Congreso (Cámara de Representantes y Senado). El presidente, por lo tanto, no necesita la confianza del Parlamento, y tampoco es responsable políticamente frente al mismo.

En definitiva, la democracia se ha considerado siempre asociada al constitucionalismo norteamericano, como mínimo a lo largo del siglo XX², pero hay que recordar que antes –al menos hasta 1870, como consecuencia de la guerra de secesión– quedó vigente el sufragio censatario masculino y la esclavitud, y que hasta 1965 no se aprobó la Ley del derecho al voto para los afroamericanos, casi cien años después de que se aprobara la 15.^a enmienda (1870) de la Constitución de Estados Unidos, que prohibía que se impidiera votar a un ciudadano por motivo de su raza, color o condición anterior de esclavitud. El caso de la segregación racial (*Separated but equal*), que no fue declarada contraria a la Constitución hasta 1954, en la histórica sentencia del Tribunal Supremo *Brown vs. Board of Education*, es un ejemplo claro de que lo que establecen las constituciones no siempre se cumple en la práctica o se interpreta muy sesgadamente.

(2) La democracia se ha considerado asociada al constitucionalismo norteamericano, pero hasta 1920 no se estableció a escala nacional el derecho a sufragio para las mujeres.

Francia

El proceso revolucionario francés se caracteriza por una ruptura radical con el *Ancien Régime* (la monarquía absoluta). El hecho que desencadenó la revolución fue la convocatoria de los Estados Generales (antiguo Parlamento estamental) por el rey Luis XVI en 1789. La fuerza de la burguesía, el antiguo tercer estado, convirtió aquel Parlamento en una Asamblea Nacional constituyente. **El primer texto que se aprobó fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)**, influida por los documentos ingleses y norteamericanos. **Después se aprobó la Constitución de 1791**, que es **la primera constitución liberal escrita del continente europeo**. A partir de 1792, Francia entra en una vorágine violenta, con la consiguiente inestabilidad política y constitucional, hasta llegar al golpe de Estado de 1799, con el cual se inicia la etapa napoleónica, que dura hasta 1814. **La experiencia francesa se caracteriza por una gran inestabilidad constitucional. La constitución deviene**

Lectura recomendada

Asamblea Nacional Constituyente francesa (1789). *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano*.

un texto que expresa los valores de la mayoría política coyuntural, en una tendencia que también se puede observar a lo largo de todo el siglo XIX en el Estado español.

La cultura constitucional francesa, en sus primeras formulaciones liberales, se fundamenta en la concepción de la «libertad pública» de las personas, en una construcción de garantía frente al Estado; en el principio de soberanía nacional, que concibe la nación como persona moral con independencia de las personas concretas y que solo puede actuar mediante representantes (Sieyès), y en el principio de imperio de la ley (*regne de la loi*), según el cual la máxima norma es la ley elaborada por el Parlamento, como expresión de la voluntad general.

3.3.2. El siglo XIX en Europa: recesión y reanudación del constitucionalismo

El constitucionalismo del siglo XIX está condicionado por la caída de Napoleón y por la Restauración monárquica defendida por los estados centroeuropeos que lo derribaron. Así se formalizó en la Conferencia de Viena de 1815. La Restauración se propone restablecer el «principio monárquico» según el cual el poder del Estado deriva del monarca, que es el centro de toda la vida política. Sin embargo, ya no será posible el regreso al poder absoluto, de modo que se aprobarán cartas otorgadas (autolimitaciones graciabiles del monarca, que acepta voluntariamente unas limitaciones a sus prerrogativas y consiente un Parlamento dócil como colaborador en algunas materias), y las constituciones pactadas, entre el rey y el Parlamento, producto de un tipo de soberanía compartida entre el rey y la nación. Es lo que se conocerá como monarquía limitada o monarquía constitucional, porque los reyes son obligados a pactar sus poderes y restringirlos.

Son ejemplos de cartas otorgadas la Carta Constitucional que Luis XVIII concedió a los franceses en 1814 (que, de hecho, fue el texto que en Europa sirvió como modelo de carta otorgada), las constituciones estamentales de los estados alemanes o la Constitución de los Países Bajos de 1815. En el Estado español, son dos las que se pueden considerar cartas otorgadas: el Estatuto de Bayona de 1808 (carta otorgada por José Bonaparte) y el Estatuto Real de 1834, que de hecho es una convocatoria de Cortes hecha por la reina regente María Cristina de Borbón y que por este motivo solo hace referencia a la organización y el funcionamiento de las cámaras sin incluir una parte dogmática o una declaración de derechos, en una mínima autolimitación de sus poderes.

Como casos de constituciones pactadas, destacan la francesa de 1830 (acordada entre el Parlamento y Luis Felipe de Orleans, que tiene un contenido más liberal que la de 1814 e inicia el desarrollo del Gobierno parlamentario), en Italia, el Estatuto Albertino de 1848 (que se convirtió en la Constitución de Italia con la unificación del país), la Constitución imperial alemana de 1871 (también después de la unificación nacional), o las constituciones españolas de 1845 y 1876.



Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836), político, eclesiástico, ensayista y académico francés, fue uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa y de la era napoleónica.

A partir de los años treinta del siglo XIX se da un proceso de democratización y de parlamentarización del constitucionalismo. El Parlamento aumenta sus poderes mediante el control del Gobierno, los monarcas pierden prerrogativas, se extienden los derechos y libertades de las personas, etc. En este contexto, encontramos la Constitución que crea el reino de Bélgica en 1831 (que recogió las dos tradiciones constitucionales europeas más relevantes, la francesa y la inglesa) y la Constitución francesa de 1848, fruto de la revolución de aquel año, que hizo abdicar al rey y proclamó la Segunda República, y que además de recoger una amplia gama de derechos individuales, abrió las puertas de la democratización estableciendo por primera vez el sufragio universal directo, e incluso algunos derechos sociales (relacionados con el trabajo, la protección del menor, la enfermedad y los ancianos). Esta misma oleada democratizadora también dio lugar a otros textos constitucionales en Holanda (1848), Suiza (1848), Dinamarca (1848), o en el Estado español (1869). En Alemania fracasó el intento de unificación bajo principios liberales y democráticos (la Constitución que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Fráncfort en 1848 nunca llegó a estar vigente), y la unificación vendrá de la mano de la Constitución imperial de 1871, que reservará al emperador importantes ámbitos de poder político en un Estado federal en el que había una clara hegemonía del Estado prusiano y de su dirigente Otto von Bismarck.

En el Reino Unido, el Parlamento se va democratizando mediante sucesivas leyes de reforma electoral desde 1832 y que culminan en 1918 con el reconocimiento del sufragio universal masculino y del femenino para mayores de 30 años, y un amplio desarrollo del parlamentarismo con un primer ministro, auténtico centro del sistema político.

3.3.3. El siglo XX: democratización y extensión del constitucionalismo

Durante el siglo XX, el constitucionalismo se asocia definitivamente a la democracia, y se extiende a prácticamente todo el mundo, a pesar de que con una calidad variable según los diferentes estados.



Otto von Bismarck (1815-1898), conocido como el canciller de hierro, fue primer ministro de Prusia y posteriormente canciller del Imperio Alemán.

La corriente democratizadora que se inició en Europa a mediados del siglo XIX culminará en el siglo XX, en cuatro etapas: el periodo de entreguerras, el final de la Segunda Guerra Mundial, los años setenta y los noventa. Tal y como destacan Fossas y Pérez Francesch, **hay una primera oleada de experiencias constitucionales, en el periodo de entreguerras**, que es consecuencia de las profundas transformaciones económicas y sociales que se produjeron en Europa y de la extensión del sufragio universal, la aparición de los partidos de masas y de la creación de nuevos estados nacionales fruto de la caída de los antiguos imperios (Austria, Alemania, Turquía). El resultado es la aparición de numerosas constituciones que, **siguiendo en buena parte la Constitución alemana de Weimar (1919) y la tendencia de la «racionalización» del poder político (recogida y teorizada por Mirkine-Guetzevitch)**, representan la generalización del sufragio universal, la supresión de las segundas cámaras aristocráticas, la sustitución de la monarquía por la república, la consolidación del sistema parlamentario, la constitucionalización de derechos sociales y la creación de los primeros tribunales constitucionales.



Boris Mirkine-Guetzevitch (1892-1955), nacido en Kiev, se tuvo que exiliar primero de Rusia y después de la Francia ocupada por los nazis. Fue profesor de derecho público en Nueva York y París, y es autor de *Constituciones de la Nueva Europa* (1928) y de *Nuevas tendencias del derecho constitucional* (1936), entre otras obras relevantes.

Entre estas constituciones destacan por las novedades que aportaron, además de la alemana de 1919, la de Austria (1920) y la de la Segunda República española (1931), pero estas orientaciones se reflejan también en los textos constitucionales de Finlandia (1919), Hungría (1920), Checoslovaquia (1920), Polonia (1921), Rumanía (1922), Irlanda (1922), Turquía (1924) y Grecia (1927). La inestabilidad social y política del periodo está marcada por la aparición de la Unión Soviética y sus constituciones de 1918, 1924 y 1936 (que inspirarán el constitucionalismo socialista en la segunda posguerra) y la ruptura con el Estado de derecho que significa el totalitarismo en Alemania (nazismo), Italia (fascismo), Portugal (salazarismo) o España (franquismo).

A raíz de la segunda posguerra, con la derrota de los regímenes totalitarios en Italia y Alemania (pero no en España ni en Portugal), **umenta la democracia constitucional, con textos tan significativos como la Constitución italiana de 1947, la Ley fundamental de Bonn (1949) o la Constitución francesa de 1958**. Estas constituciones ejercerán una gran influencia en algunas de las monarquías parlamentarias europeas (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia), y **serán una de las principales referencias para las constituciones de los años setenta**, entre las cuales están las de los estados del sur de Europa que iniciaron una transición hacia la democracia, como Portugal o Grecia en 1975, y el Estado español en 1978. En una última etapa del siglo XX, durante los años noventa, con la caída del comunismo en los países de Europa del este, se elaborarán nuevas constituciones que en general responden a los principios del constitucionalismo del Estado social y democrático de derecho y en las que toma fuerza el sistema semipresidencial como forma de gobierno.

En síntesis, **el siglo XX ve cómo se consagra el Estado social y democrático de derecho, la normatividad constitucional plena** –para ciudadanos y poderes públicos– **y suprema mediante el control constitucional de las leyes**, y se reformula la vieja idea del *judicial review* norteamericano **mediante**

el control concentrado en manos de tribunales constitucionales. Así, en las constituciones del siglo XX, **se consolida la legitimación exclusivamente democrática del poder** con el reconocimiento de la soberanía popular, el derecho de sufragio universal, la participación popular en la elaboración y revisión de las constituciones, y en el funcionamiento de los poderes públicos. Y también será habitual que los textos constitucionales incorporen cláusulas reguladoras de la intervención estatal en el proceso económico y proclamen derechos económicos, sociales y culturales. En cambio, la garantía de la diversidad y del pluralismo será uno de los retos más complejos y en parte todavía pendientes, junto con el mantenimiento de un Estado social que haga posible que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.

4. La constitución y la justicia constitucional

4.1. Concepto, contenido y funciones de la constitución

El concepto actual de constitución está vinculado al constitucionalismo y a la aparición del Estado y la sociedad liberal y del movimiento codificador. Como ya se ha visto, el concepto moderno de constitución nace con el triunfo de las ideas liberales, a las cuales se añadirán posteriormente las democráticas, y se construye sobre los fundamentos ideológicos del constitucionalismo, mencionados también anteriormente.

El concepto de constitución se caracteriza por su carácter normativo, lo cual supone que un sistema de normas jurídicas –es decir, vinculantes– crean y ordenan un orden político, y son delimitadas en un documento escrito (constitución formal) que tiene el atributo de la supremacía; es decir, de norma suprema, de la que derivan el resto de las normas (*norma normarum*).

La elaboración de la constitución es un acto mediante el cual los detentores del poder, de la soberanía, generan un nuevo orden político actuando como poder constituyente. El acto constituyente puede ser de naturaleza más o menos inclusiva de los miembros de la sociedad, a pesar de que, en principio, en toda sociedad democrática la soberanía emana del pueblo y este siempre tendría que poder influir decisivamente en el acto constituyente, del que derivan los poderes constituidos, creados por el texto constitucional. El procedimiento para elaborar la constitución es diferente del seguido para el resto de las leyes, y el procedimiento de su reforma también es específico y más dificultoso (rigidez). El contenido de la norma constitucional es aquel que deriva de los principios liberales de la limitación y control del poder político mediante la separación de poderes y la garantía de la libertad de los ciudadanos.

Las características anteriores definen el concepto normativo o racional-normativo de constitución, diferente de otras acepciones que tienen en cuenta elementos históricos o sociológicos que configuran la vida política de un país. Las definiciones doctrinales de «constitución» han sido múltiples, pero es posible ordenarlas en torno a tres grandes concepciones: la racional-normativa, la histórico-tradicional y la realista o sociológica.

La concepción racional-normativa se opone a la concepción histórica de constitución, que es de raíz tradicionalista y contrarrevolucionaria, y considera que cada pueblo tiene su propia y particular constitución nacional, que es fruto de su historia y expresa sus rasgos característicos, porque por debajo de las leyes derivadas de la voluntad humana los pueblos tienen una personalidad y unas exigencias constitucionales que hacen que su constitución sea indisponible (aunque reformable de acuerdo con la evolución de los tiempos). La constitución de un pueblo, por lo tanto, no es un sistema normativo producto de la razón, sino el resultado de una transformación histórica (en la cual a menudo intervienen factores irracionales o fortuitos); la constitución no es el resultado de un acto único del poder constituyente, sino la sedimentación de la tradición y la historia. Esta concepción, propia de los contrarrevolucionarios y de los liberales doctrinarios, fue elaborada por el irlandés Edmund Burke y los franceses Louis de Bonald y Joseph de Maistre.



El irlandés Edmund Burke (1729-1797) fue escritor y pensador político conservador, y sus *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, uno de los más famosos ataques a esta revolución.

La concepción realista o sociológica se puede entender como complementaria de la racional-normativa, dos perspectivas o puntos de vista que se pueden enriquecer mutuamente. Para la concepción realista o sociológica, la constitución es la manera política real de ser de un pueblo, en la línea de la *politeia* de Aristóteles, y, por lo tanto, consideran que la norma constitucional formal sería una simple «hoja de papel» (Ferdinand Lassalle) porque a menudo indica poco sobre la distribución y el funcionamiento real de los poderes existentes en una comunidad política; esta concepción es crítica con la pretensión de tratar solo las normas jurídicas sin atender a su eficacia, y ha sido formulada tanto por conservadores (ante las pretensiones liberales de dictar normas utópicas) como por reformistas o revolucionarios.



Louis Gabriel Ambroise, vizconde de Bonald (1754-1840), político y filósofo francés, es uno de los exponentes más importantes del pensamiento católico tradicionalista de los años que siguen a la Revolución Francesa. Contribuyó a sostener el proceso de Restauración borbónica que experimentó Francia entre 1815 y 1830 y, en general, en Europa entre los años 1814 y 1848.

Por todo esto, hoy día **el término constitución se usa en tres sentidos diferentes, que responden a tres conceptos de constitución** (Isidre Molas):

- De acuerdo con **el concepto formal de constitución**, es la norma jurídica que se distingue del resto de las normas del ordenamiento jurídico para tener una forma propia y específica derivada de su jerarquía normativa, del órgano que lo ha aprobado o del procedimiento especial para reformarla.
- De acuerdo con **el concepto material de constitución**, es el conjunto de normas jurídicas que, con independencia de su carácter formal, regulan determinados aspectos esenciales de la comunidad política, especialmente la forma de Estado, la organización y funcionamiento de los poderes públicos y los derechos fundamentales.
- De acuerdo con **el concepto de constitución sustancial** (o constitución en sentido material), es la forma o manera de ser de una comunidad política, es decir, la organización real del poder político y del proceso político, además de las reglas jurídicas o fácticas de su funcionamiento.



Joseph de Maistre (1753-1821), teórico político y filósofo, es el máximo representante del pensamiento conservador opuesto a las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Su principal obra política, *Consideraciones sobre Francia* (1797), presenta la Revolución Francesa como un acontecimiento radicalmente malo, tanto por sus causas como por sus efectos.

Con el fin de ayudar a comprender mejor el concepto de constitución y sus diferentes características, la doctrina ha establecido distintas clasificaciones, a partir de los criterios siguientes (Álvarez Conde):

- **Teniendo en cuenta la titularidad del poder constituyente, se distingue entre cartas otorgadas, pactadas o constituciones democráticas.** Las cartas otorgadas son actos unilaterales del monarca (habitualmente debidos a la presión popular), en los que este autolimita su poder, desprendiéndose de algunas prerrogativas en favor del Parlamento; podemos encontrar ejemplos de ello en Francia (1814), Alemania (1815), Japón (1889), Mónaco (1911) o España (1808 y 1834), entre otros. Las cartas pactadas son propias de la etapa del liberalismo doctrinario y son producto del acuerdo entre el rey y el Parlamento, que actúa como representante del pueblo, en lo que se podría considerar una cosoberanía o soberanía compartida; como ejemplo, se pueden citar la Constitución francesa de 1830, la prusiana de 1850 o las españolas de 1837, 1845 y 1876. Las constituciones democráticas parten del reconocimiento de una única legitimidad posible, la soberanía popular; son ejemplos tempranos de esto las francesas de 1791 y 1848, y hoy día la mayoría de las constituciones del mundo occidental.
- **Por razón de su forma, las constituciones pueden ser escritas o no.** Actualmente son escritas, aunque Canadá o el Reino Unido de Gran Bretaña tienen una constitución en parte no escrita. Además, las constituciones escritas pueden estar contenidas en un único documento (codificadas) o en varios.

Como hemos visto, como consecuencia del racionalismo y de la voluntad codificadora surgida a principios del siglo XIX, hoy día la mayoría de las constituciones están contenidas en un único documento, aunque la constitución de la III República francesa estaba repartida entre varios documentos, como lo están también, entre otras, la actual constitución británica, la canadiense (que es una amalgama de actas codificadas, tradiciones no codificadas y convenciones), la austríaca (que, además de la Ley constitucional federal de 1920, incluye un centenar de leyes federales, las disposiciones de carácter constitucional que son recogidas en leyes federales ordinarias –que son aproximadamente un millar– y varios tratados internacionales), o la de la República Checa (la denominada Constitución de 1992 es propiamente una ley constitucional, y junto con otras leyes constitucionales constituye el denominado ordenamiento constitucional de la República Checa).



¿Qué es una constitución? (1831) es la obra más conocida de Ferdinand Lassalle (1825-1864), abogado y político socialista alemán y uno de los principales divulgadores de «la ley de hierro de los salarios», que afirma que los salarios reales a la larga siempre tienden al salario mínimo para sostener la vida de los trabajadores.

- **Según su procedimiento de reforma, se distingue entre constituciones rígidas y flexibles**, de acuerdo con la denominación de Bryce (1901). Las constituciones rígidas, que son la inmensa mayoría, tienen un procedimiento específico de reforma, diferente y generalmente más agravado y complejo que el de reforma de las leyes ordinarias. Las constituciones flexibles no contienen un procedimiento específico para su reforma y, por lo tanto, se pueden modificar siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.
- **Según el grado de eficacia de las constituciones, Loewenstein las clasifica entre normativas, nominales y semánticas**. En las primeras, se produce una identificación entre la previsión del texto constitucional y la realidad de la vida política, que se aleja en las nominales y que llega a ser un disfraz en las últimas. Es decir, las semánticas son jurídicamente válidas pero lo que estipulan no se corresponde nada con la dinámica real del proceso político, porque en el fondo son constituciones que enmascaran las fuerzas reales que detentan el poder y que tienen básicamente la función de ser una tapadera formal de una situación política absolutamente manipulada por los que realmente detentan el poder, de manera independiente de lo que establece la constitución formal.
- **Según la diversidad y la extensión de las materias que contienen, las constituciones pueden ser breves o extensas**. En general, las constituciones breves son características del sistema liberal porque forma parte de esta ideología un Estado mínimo y una constitución que básicamente se limite a establecer un derecho fundamental y a regular las reglas de juego del Estado (la organización y funcionamiento de sus órganos). En cambio, una constitución es larga no solo por el número de artículos que contiene, sino sobre todo por la voluntad del constituyente de incluir todas las materias propias de un Estado social y democrático de derecho, es decir, además de las que hacen referencia a los poderes del Estado, también las que implican fijar unos objetivos de la política social y económica a estos poderes estatales. La Constitución portuguesa de 1976 y la española de 1978 serían ejemplos de constituciones extensas. Un ejemplo de constitución breve sería la de Estados Unidos de 1787, no solo porque únicamente contiene originalmente 7 artículos (y posteriormente 27 enmiendas), sino por esta concepción liberal a la que responde.
- **Según la función que predomine, se habla de constitución-proceso o constitución-programa (o constitución dirigente)**. La constitución-proceso tiene como función principal ser un instrumento garantista que limita los poderes, un dispositivo formal que establece las reglas procedimentales para garantizar un proceso político abierto en una pluralidad de opciones sociales, y que por lo tanto se limita básicamente a regular la organización y el funcionamiento de los poderes del Estado. Sería el caso de la Constitución de Estados Unidos de 1787. En cambio, se considera una constitución-programa o constitución dirigente la que tiene como función



Karl Loewenstein (1891-1973), autor de *Teoría de la constitución* (1959), fue un jurista y profesor de ciencia política alemán que se tuvo que exiliar de la Alemania nazi en Estados Unidos, donde destacó por sus investigaciones sobre la tipología de las constituciones.

principal fijar un programa transformador de la sociedad que los poderes públicos tienen que desarrollar, es decir, predomina una función programadora que quiere establecer unas finalidades sociales al Estado y unos objetivos y unas tareas políticas a los poderes constituidos. Es un ejemplo de esto la Constitución portuguesa de 1976. Aun así, estas dos maneras de concebir la constitución se pueden considerar complementarias.

En cuanto al contenido de las constituciones, la doctrina ha debatido bastante sobre si había o no una «materia constitucional», es decir, un mínimo irrenunciable, un contenido característico y típico de cualquier constitución. En la práctica, **los contenidos de las constituciones son variables, pero en nuestra cultura jurídica y política se constata que hay unas materias que habitualmente sí contienen los textos constitucionales: los valores y principios básicos del orden político estatal; el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los grupos, la organización de los poderes del Estado y la reforma de la misma constitución.**

Algunos estudiosos han defendido la existencia irrenunciable de este contenido, porque son los aspectos que definen la función política de la constitución: la organización de los poderes del Estado de acuerdo con el principio de división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Otros han criticado esta perspectiva universalista del contenido constitucional propugnando una visión más multicultural del derecho y, por lo tanto, también de las constituciones y los derechos que contienen.

Tradicionalmente, este contenido se ha estructurado en dos grandes partes: una parte orgánica (organización, competencias y funcionamiento de los poderes públicos a partir del principio de separación de poderes) **y una parte dogmática** (garantía de los derechos y principios básicos del sistema político instaurado). Esta distinción era relevante porque hasta que no se impone plenamente el concepto racional-normativo de constitución, que establece que toda la constitución es norma jurídica y suprema, en muchos estados (incluido el español) a menudo solo se entendía como jurídicamente vinculante la parte orgánica, de tal manera que los derechos recogidos en la constitución solo tenían eficacia en la medida en que eran regulados por el legislador. De hecho, hasta la Constitución belga de 1831 lo más frecuente era que las constituciones no tuvieran una parte sistemáticamente dedicada a los derechos y libertades, sino que muchas veces las declaraciones de derechos figuraban en un texto aparte. Este es el caso del primer texto de la Constitución de Estados Unidos de 1787, que incorporó los derechos posteriormente (como *Bill of Rights*), y también de la Constitución actual francesa de 1958, que todavía remite a la Declaración de 1789. En la actualidad, esta es una distinción con un valor básicamente académico, que puede ayudar a entender la diversidad del contenido de las constituciones, pero que tal y como remarcan Fossas y Pérez Francesch, de acuerdo con la idea genuina del constitucionalismo, no se pueden desvincular las normas organizativas de las dogmáticas porque forman una estructura inseparable, hasta el punto de que a menudo resulta difícil distinguir en una misma norma el carácter dogmático del orgánico, y también

es una diferenciación poco útil y adecuada porque la distinción no capta la complejidad de los textos constitucionales actuales, que contienen una amplia tipología de normas imposible de reducir a un esquema dual.

Por otro lado, en cuanto a las funciones de la constitución, hay que tener presente que frecuentemente los textos constitucionales (a menudo en los preámbulos) expresan los objetivos que, según los redactores, se proponen lograr. Sin embargo, en general, y partiendo de los fundamentos del constitucionalismo, **las funciones de una constitución** se pueden sistematizar en las siguientes:

- **Constituir el Estado**, es decir, crear la organización estatal, delimitando los elementos constitutivos del Estado y determinando la estructura de los poderes públicos.
- **Legitimar los poderes del Estado**, porque la misma idea de constitución introduce una legitimación racional del poder político por el hecho de que no deriva de la fuerza, ni de la voluntad de un monarca, ni es predeterminada por la historia, sino que lo que legitima el poder político es la misma constitución, que es garantía de la limitación de los poderes y respeto de los derechos fundamentales. El poder solo puede ser ejercido por los órganos creados por la constitución, que limita sus potestades y obliga a que su actividad se fundamente en lo que dispone la misma constitución. Tal y como remarca Víctor Ferreres, el problema que para el liberalismo democrático plantea la existencia de un Estado que impone sus poderes sobre los individuos (que puede imponer deberes de manera unilateral, sin el consentimiento del destinatario) se resuelve exigiendo que todos los órganos estatales, sin excepción, deriven su existencia y sus competencias de la decisión soberana del pueblo expresada en una constitución. Así, para Thomas Paine (uno de los más importantes propagadores de las nuevas ideas liberales durante las revoluciones norteamericana y francesa), el poder público se puede ejercer por usurpación o por delegación. Solo en este segundo caso es legítimo su ejercicio; el poder se ejerce por delegación cuando el pueblo ha podido decidir de manera libre (sin estar vinculado a decisiones políticas tomadas por generaciones del pasado) cuál es la configuración del Estado bajo el cual tiene que ser gobernado, y esta decisión soberana del pueblo se expresa en la constitución.
Por lo tanto, toda la legitimidad del sistema constitucional reposa en la traslación de poder que hay del pueblo a los representantes por medio del acuerdo de este pueblo mediante el acto constituyente. Hay que tener claro este punto para ver qué es lo que puede hacer tambalear los fundamentos de cualquier constitución: la falta de relación real entre el pueblo y el hecho de haber decidido sobre cómo sería la constitución.
- **Limitar y racionalizar los poderes del Estado**, dado que define las competencias del Estado y atribuye las competencias fundamentales a cada uno de los poderes públicos, los procedimientos para tomar decisiones, las relaciones entre ellos y sus controles. Esta función limitadora de los

Lectura recomendada

Víctor Ferreres (2000). «Teoría general de la Constitución». En: Gerpe, M. (coord.). *Dret constitucional I* (págs. 82-89). Barcelona: UOC.



El inglés Thomas Paine (1737-1809) fue un escritor y divulgador en Francia y Estados Unidos de las ideas revolucionarias, con obras como *El sentido común* (1776), el más famoso de los folletos imprimidos en la época (que logró una tirada de medio millón de ejemplares) o *Los derechos del hombre* (1791) como respuesta a *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, de Edmund Burke.

poderes estatales también contribuye a reforzar la legitimación del Estado porque, desde el punto de vista del liberalismo democrático, el objetivo último del Estado es la protección de los derechos fundamentales y uno de los medios para conseguirlo es la división y limitación de los poderes para que unos controlen a los otros y aseguren no solo que el Estado no viola derechos, sino que es el que garantiza que se puedan ejercer en plenitud.

- **Ordenar la producción jurídica**, como «norma de las normas», estableciendo los criterios para que los distintos sujetos puedan producir normas jurídicas. Por lo tanto, la constitución no es solo la fuente de la que determinados órganos derivan su poder de dictar normas jurídicas sino que, además, cuando la constitución establece unos criterios limita el contenido posible del ordenamiento jurídico (ciertos contenidos potenciales del ordenamiento pueden ser excluidos por las limitaciones materiales que la constitución puede imponer), y también orienta positivamente el contenido del ordenamiento (por la exigencia de satisfacer ciertos objetivos que la constitución puede fijar).
- **Fundamentar el orden estatal**, puesto que la constitución establece un sistema de valores que son la base y dan sentido a las actuaciones de los poderes públicos. Estos principios materiales insertados en la constitución son un parámetro para juzgar si las normas y los actos de los poderes públicos son contrarios a la constitución (y, por lo tanto, son un marco básico que actúa como límite), y a la vez son unos criterios para orientar e inspirar la actividad de los poderes constituidos.
- **Transformar la sociedad**, mediante normas finalistas y mandatos de intervención a los poderes públicos. Esta función es más propia de las constituciones-programa o dirigentes que, además de establecer un Estado democrático, apuestan también por un Estado de carácter social.

4.2. Elaboración y reforma de la constitución

4.2.1. La elaboración de las constituciones

Dejando de lado los pocos casos ya mencionados de constituciones en parte no escritas y no codificadas en un solo documento (como por ejemplo las del Reino Unido de Gran Bretaña o Canadá), **la constitución se elabora por lo que se denomina poder constituyente, dotado de las características teóricas de ser originario** (no derivado de ningún otro poder), **ilimitado** (porque no está condicionado ni formal ni materialmente por ninguno otro poder), **prejurídico** (es un poder puramente fáctico, previo a la constitución y al ordenamiento jurídico que se derivará del mismo) y **único** (se expresa una sola vez y el resultado es el texto constitucional que será el fundamento de los poderes constituidos). Es un concepto que se identifica con el de soberanía, de mo-

do que se considera que quien es soberano puede ejercer el poder constituyente, tiene la capacidad para hacer la constitución. **Quien es titular del poder constituyente es soberano y por eso elabora la constitución libremente**, como producto de su voluntad. **Hoy, desde la perspectiva democrática, el pueblo es el titular del poder constituyente** y de la soberanía, como fuente de legitimidad de los poderes establecidos en la constitución.

Las características teóricas del poder constituyente se pueden observar mejor en casos como procesos revolucionarios o de independencia, en los cuales es más fácil partir de cero (aunque tampoco en estos casos se parte nunca de la nada), pero la mayoría de las veces hay condicionamientos fácticos o del seguimiento de reglas procedimentales que hacen que el poder constituyente no se pueda expresar con todas sus potencialidades y con el carácter ilimitado que teóricamente se le supone. En todo caso, es importante tener en cuenta el proceso constituyente para valorar el grado de legitimidad inicial del texto constitucional que resulte aprobado.

El ejercicio del poder constituyente en el marco de la actual democracia representativa **se lleva a cabo mediante un proceso constituyente**, conjunto de procedimientos y actos mediante los cuales se elabora la constitución. No hay un único modelo de proceso constituyente, un proceso estándar. **Habitualmente, las constituciones son elaboradas por una asamblea o convención constituyente**, elegida con esta finalidad, que tiene como misión exclusiva la discusión y aprobación de una constitución. Una vez hecha la constitución, se disuelve y se convocan nuevas elecciones para elegir una asamblea legislativa ordinaria (como uno de los poderes constituidos).

También es habitual convocar un referéndum para que el pueblo directamente ratifique la constitución. Sin embargo, este procedimiento más habitual (de asamblea constituyente más referéndum popular) ha tenido notables excepciones, como la Ley fundamental de Bonn, elaborada a partir de las instrucciones de las fuerzas aliadas a los *Länder* alemanes, que después recogió una asamblea constituyente³; es un caso similar al de la Constitución japonesa de 1947, que también fue aprobada por el Parlamento japonés (Dieta), siguiendo un modelo que habían elaborado un equipo de expertos extranjeros durante la ocupación militar (mayoritariamente de Estados Unidos) que vino como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial; también son singulares los casos de la Constitución francesa de 1958 (el Parlamento delegó en el Gobierno del general De Gaulle la elaboración del texto que después se sometió a referéndum) o el de la Constitución española de 1978, que es elaborada en un proceso constituyente *de facto* en aplicación de la Ley para la reforma política de 1976 (última de las leyes fundamentales franquistas), por unas cortes bicamerales, por acuerdo de una amplia mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Finalmente, un caso remarcable de uso del referéndum es el italiano: en 1946, justo antes del inicio del proceso constituyente, los italianos fueron llamados a las urnas para dos votaciones paralelas; una era la que eligió la Asamblea constituyente encargada de redactar la constitución, y la otra,

⁽³⁾La Ley fundamental de Bonn de 1949 fue redactada por un Consejo parlamentario (nombrado por los gobiernos de los once estados federados de Alemania Occidental, bajo el mando militar de las zonas de ocupación norteamericana, británica y francesa), que posteriormente la aprobó por mayoría absoluta (pero con varias voces en contra, como la del partido comunista o la del Parlamento de Baviera), y fue ratificada por los gobernadores militares y por los parlamentos de los estados federados.

un referéndum para elegir entre monarquía o república; dado que la mayoría optó por la república, la Asamblea constituyente recibió el encargo de hacer una constitución republicana.

Por lo tanto, a pesar de que hay un marco teórico, las particularidades de la práctica son muy notables. Y lo que resulta importante es analizar los distintos elementos de cada proceso constituyente para valorar en conjunto hasta qué punto se puede considerar que tiene legitimidad de origen la constitución que surja del mismo.

4.2.2. La reforma de las constituciones

La mayoría de las constituciones tienen vocación de permanencia o perdurabilidad, y no prevén su caducidad. Hay una excepción en el artículo 146 de la norma suprema alemana, que establece que la Ley fundamental de 1949 dejará de regir el día que entre en vigor una constitución que haya sido aprobada libremente por el pueblo alemán. Con este precepto, se subraya la decisión de haber adoptado una «ley fundamental» y no una «constitución», porque a pesar de que a menudo se utilizan estos dos términos como sinónimos, los constituyentes consideraron que la manera en que se redactó este texto, bajo la ocupación militar y con la ausencia de representantes del sector oriental del país, no permitía elaborar una constitución definitiva, sino solo un texto provisional. Aun así, el texto se consolidó y actualmente rige para la Alemania reunificada.

Aunque hasta hoy son pocas las constituciones que han conseguido tener una larga vida (a pesar de que la mayoría tengan vocación de permanencia o perdurabilidad), **todas las constituciones necesitan una evolución progresiva para adaptarse a los cambios sociales y políticos de cualquier sociedad libre.** Si una constitución democrática en origen se aleja de la realidad que quiere regir y va perdiendo aceptación popular hasta llegar a chocar con la voluntad mayoritaria del pueblo al cual en principio tendría que servir, aquel texto constitucional pierde legitimidad (y la pierde también la actuación de los poderes públicos) y **si no se encuentra la manera de adaptarla de nuevo a los cambios y a las demandas sociales, puede acabar generando** más problemas de los que resuelve y provocando tensiones que conduzcan no a una reforma (por los procedimientos previstos), sino a una **ruptura constitucional**, es decir, una ruptura jurídica que signifique un punto y aparte respecto al anterior régimen político (la sustitución global de un sistema político por otro sin seguir los procedimientos de reforma establecidos). Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, expuso la necesidad de que las sociedades pudieran decidir cada 19-20 años si querían seguir con la constitución vigente o cambiarla; se trata de una cláusula que debería permitir que cada generación pudiera actuar con toda la libertad propia de un poder soberano y, por lo tanto, constituyente, en lugar de actuar dentro de un marco

de reforma predeterminado por un poder constituyente anterior que relega la sociedad del momento a un soberano «descafeinado» o poder constituyente constituido.

Un procedimiento de reforma constitucional muy complejo y dificultoso, a pesar de que pueda parecer que teóricamente puede ser un elemento de estabilidad, **puede acabar siendo un factor de conflicto social** y que acabe implicando inestabilidad. La estabilidad de un texto constitucional, en principio, se puede considerar positiva porque puede permitir un mejor conocimiento popular de la constitución y un mayor arraigo de sus valores; pero si esta estabilidad deviene solo formal (perdurabilidad de un mismo texto), porque es a expensas de la pérdida de aceptación social y, por lo tanto, de legitimidad, ya no se puede considerar positiva. Si hacemos un repaso a los principales textos constitucionales, veremos que **algunas constituciones han sido reformadas muchas veces** (por ejemplo, unas sesenta la Ley fundamental alemana de 1949) **y otras muy pocas o ninguna** (como por ejemplo la Constitución de Japón, de 1947, que desde entonces no ha sido modificada ni una sola vez). En medio hay países como Irlanda, donde, desde que se aprobó la actual constitución en 1937, ha sido reformada 29 veces (con 35 intentos de reforma, algunos de los cuales no han logrado la mayoría suficiente para salir adelante). Pero estos datos por sí solos no nos indican el grado de eficacia de las constituciones, ni tampoco el nivel de satisfacción de los ciudadanos con su norma fundamental, sino más bien la flexibilidad del procedimiento o la cultura política de reforma de aquella sociedad.

Tal y como remarca Eduardo Espín, **la reforma constitucional no es, sin embargo, la única vía de evolución constitucional, sino que hay otro procedimiento más lento y de carácter progresivo, pero no por eso menos útil, como es la labor de la jurisprudencia constitucional**. Tanto en los países que han adoptado el sistema europeo o modelo concentrado de justicia constitucional (con la introducción de los tribunales constitucionales), como en los países que han apostado por el sistema norteamericano o modelo difuso (con la función que lleva a cabo el Tribunal Supremo), modelos que explicaremos en el apartado siguiente de este módulo, **la interpretación de la constitución ha llegado a ser de una indiscutible actualidad y relevancia**. Y esta interpretación puede ser una vía de actualización de los contenidos de los preceptos constitucionales (a menudo de naturaleza genérica o con una cierta ambigüedad o polivalencia), que **puede llevar a cabo también eficazmente la tarea de adaptación de la constitución a la sociedad**, que es siempre cambiante por su propia naturaleza.

La modificación formal del texto de la constitución corresponde al poder de reforma constitucional. El poder constituyente, al elaborar la constitución, renunciaría a modificarla cuándo y cómo quisiera, de forma que lo otorgaría al poder de reforma, de revisión, o denominado también poder constitu-

Web recomendada

Ved la página web de Comparative Constitutions Project.

Lectura recomendada

Eduardo Espín (1994). «La Constitución como norma». En: López Guerra y otros (1994). *Derecho constitucional* (vol. 1, págs. 50-58). Valencia: Tirant lo Blanch.

yente-constituido o derivado. De este modo, el poder constituyente se auto-limita y acepta que la reforma se haga por los órganos y mediante los procedimientos establecidos por él mismo.

Cuando los procedimientos son iguales que los que se establecen para modificar las leyes ordinarias, se habla de **constituciones flexibles**, mientras que cuando son específicos y generalmente más complejos y agravados, se habla de **constituciones rígidas**. Así pues, **la rigidez constitucional es la característica que tiene una constitución cuando no se puede reformar por el procedimiento legislativo ordinario, y es un mecanismo importante para garantizar la estabilidad del texto y, por lo tanto, para asegurar su supremacía normativa.** Hoy día, la mayoría de las constituciones son rígidas, a diferencia de lo que fue frecuente en el siglo XIX en Europa. Irlanda y Dinamarca son los únicos países dentro de la Unión Europea donde es obligatorio someter a consulta popular cualquier cambio del texto constitucional, una característica solo compartida dentro de la Europa occidental por Suiza (Eva Pons).

Los teóricos se han ocupado de los **límites a la reforma de la constitución** y han distinguido entre **los límites explícitos** (establecidos de manera expresa por la misma constitución) y **los implícitos** (deducibles de la misma norma en la medida en que esta contiene algunos aspectos que se consideran esenciales o básicos, como por ejemplo los derechos fundamentales, el principio democrático o sus principios estructurales). Unos y otros límites, pero especialmente los implícitos, han sido desarrollados teóricamente y en la práctica, sobre todo a partir de la preocupación que generó la experiencia de los totalitarismos del periodo de entreguerras, y la destrucción que hicieron de los textos constitucionales y de los valores democráticos. Por su parte, **los límites explícitos pueden ser temporales y materiales.** Estos últimos se denominan también «**cláusulas de intangibilidad**», es decir, prohibiciones de reformar determinadas materias o preceptos.

Por ejemplo, contienen límites temporales (prohíben la reforma en un periodo de tiempo o bajo determinadas circunstancias) la Constitución francesa de 1791 (se prohibía cualquier reforma hasta que hubieran pasado cuatro años); la Constitución española de 1812 (ocho años); la Constitución belga de 1831 (que prohíbe la reforma en periodos de regencia); la portuguesa de 1976 (no se puede revisar la Constitución hasta que hayan pasado cinco años desde la última revisión ordinaria); o la Constitución española de 1978 (prohíbe iniciar la reforma en tiempo de guerra y durante la vigencia de algunos de los estados excepcionales). Y en cambio, entre otros muchos, podemos encontrar ejemplos de cláusulas de intangibilidad en el art. 79.3 de la Ley fundamental de Bonn (la organización territorial del Estado de forma federal o el modelo de Estado democrático y social de derecho); el art. 89 de la Constitución francesa de 1958 (prohíbe la reforma cuando afecte a la integridad territorial o la forma republicana de Gobierno); el art. 139 de la Constitución italiana de 1947 (prohíbe la reforma de la forma de Gobierno republicana); el art. 110.1 de la Constitución de Grecia de 1975 (no puede ser objeto de revisión la forma del régimen político como república parlamentaria, entre otras materias); el art. 281 de la Constitución de Guatemala de 1985 (que establece como irreformable la forma republicana de Gobierno, también entre una lista bastante extensa de materias); o el art. 9.2 de la Constitución de Chequia de 1992 (que no solo prohíbe modificar los elementos sustanciales del Estado democrático de derecho, como encontramos en la constitución alemana, sino que extiende la prohibición a la interpretación de las normas –art. 9.3–, de tal manera que no se podrá usar para eliminar o poner en peligro los fundamentos del Estado democrático).

Lectura complementaria

Eva Pons (2016). «La reforma de la Constitució d'Irlanda de 2015: democràcia deliberativa i canvi constitucional. *Eines* (núm. 25, págs. 52-65).

Para evitar incluir cláusulas de intangibilidad, **algunas constituciones prevén dos procedimientos de reforma constitucional, con un grado de rigidez más elevado para determinadas materias que se consideran fundamentales** del sistema político. Esta opción suele responder a la convicción de que imponer límites materiales a la reforma (cláusulas de intangibilidad) no es una barrera eficaz para impedir cambios políticos, porque precisamente en las cuestiones esenciales es donde, si se da el caso, la acción política se puede imponer por encima de las vías constitucionales, haciendo inútiles las previsiones del constituyente (Eduardo Espín).

Encontramos un ejemplo de esta opción de dos procedimientos de reforma en la Constitución española de 1978, en la que lógicamente no hay ninguna cláusula de intangibilidad y, por lo tanto, de acuerdo con una interpretación literal del texto, cualquier materia se puede reformar e, incluso, sería posible una revisión total del texto, eso sí, siguiendo en todo momento el procedimiento establecido. Aun así, **se ha discutido si todo es reformable, teniendo en cuenta la idea de los límites implícitos**, puesto que, por ejemplo, se podría reformar el principio democrático y esto no sería una reforma, sino una destrucción de la Constitución española. También se ha discutido si es admisible una reforma del art. 168 CE (que contiene el procedimiento agravado de reforma) mediante el art. 167 (procedimiento ordinario), puesto que si bien no está prohibida, podría significar dejar sin protección las materias que el constituyente colocó en aquel artículo para exigir para su reforma unas mayorías todavía más reforzadas. En este caso y en general, respecto a las cláusulas de intangibilidad en los países que las tienen, algunos autores han hablado de la posibilidad de superar estas prohibiciones mediante un proceso de reforma en segundo grado, es decir, modificando el precepto que prohíbe la modificación. Sin embargo, también hay quien considera que esto es un fraude a lo que establece la constitución. Es un debate jurídico abierto, sobre un fondo político (como casi siempre en los grandes temas del derecho, al menos, del derecho constitucional).

En cualquier caso, **las cláusulas de intangibilidad tienen un significado político importante porque vienen a establecer lo que se considera el núcleo esencial de la constitución, indisponible para el poder de reforma** (y solo se podrían cambiar en caso de un proceso revolucionario o de ruptura con la legitimidad constitucional).

Aparte de las modificaciones formales de la constitución (reforma), **también puede haber mutaciones constitucionales, que son cambios en el sentido del texto de la constitución sin que esta se modifique formalmente**. Hablaremos de ello en el apartado «La constitución y la justicia constitucional», cuando expliquemos las características de la interpretación de la constitución.

Jurídicamente la rigidez es, pues, una protección para la constitución mediante el establecimiento de un límite para el legislador, límite verificable, además, mediante el control de constitucionalidad de la ley. Sin reforma de la consti-

tución no se podría imponer el control de constitucionalidad de la ley, pero sin control de constitucionalidad de la ley, el límite que la reforma representa podría ser traspasado sin ser sancionado.

4.3. Las garantías de la supremacía normativa de la constitución. Los modelos originarios y derivados de justicia constitucional

La expresión «justicia constitucional» se utiliza principalmente en dos sentidos. En un sentido estricto o restringido, entendemos por justicia constitucional los sistemas de control político o jurisdiccional de las leyes para asegurar su respeto a la constitución. En un sentido más amplio, también se habla de justicia constitucional incluyendo no solo los mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes, sino también todos los procesos de defensa de la constitución, como por ejemplo los conflictos entre entes territoriales autónomos o entre órganos constitucionales, la protección de los derechos fundamentales e, incluso, el conocimiento de las causas contra las altas magistraturas del Estado. En este sentido amplio, el concepto de justicia constitucional se aproximaría bastante a lo que se denominó históricamente «defensa de la constitución», que comprende mecanismos tan diferentes como los procedimientos agravados de reforma constitucional, la distribución del poder entre varios órganos que se controlan recíprocamente o la previsión de los estados de excepción para circunstancias de crisis política que amenazan el orden constitucional.

Son varias también las expresiones que se han usado para referirse a estas actividades de garantía de la superioridad normativa de la constitución, aunque no son propiamente sinónimas porque tienen un alcance más o menos amplio. A partir de Carl Schmitt, en el ámbito germánico se utilizó primero la definición de *defensa de la constitución* y después la de *justicia constitucional* a partir de la Constitución de Weimar de 1919; en Francia se usó preferentemente el concepto de *control de la constitucionalidad*, mientras que un sector de los juristas italianos se refieren a la *jurisdicción constitucional* o al *proceso constitucional*; para los angloamericanos, la denominación más frecuente es la de revisión judicial de la constitución (*judicial review*).

Sin embargo, tanto si nos referimos a la justicia constitucional en un sentido amplio como estricto, y tanto si usamos esta expresión o alguna otra (como defensa de la constitución, control de constitucionalidad, jurisdicción constitucional o revisión judicial de la constitución), partimos de un mismo fundamento: el concepto de constitución como norma suprema, porque si la constitución establece las condiciones formales y materiales de validez de las normas inferiores, es lógico y necesario que se articulen mecanismos para reaccionar contra las normas que hayan sido dictadas sin respetar estas condiciones de validez. Por lo tanto, los diferentes sistemas de justicia constitucional son propios de los estados que parten del carácter supremo de la constitución que, como hemos visto, hoy día son la mayoría de los estados (pero no todos) que se pueden considerar una democracia. Así pues, la existencia de la justicia constitucional exige un presupuesto previo: la supremacía normativa de la constitución.

Lectura recomendada

Víctor Ferreres (1997). *Justicia constitucional y democracia*. Madrid: CEPC.

Nota

Dado que en la asignatura «Derecho constitucional» ya se explican los distintos procedimientos que se pueden incluir en un sentido amplio de justicia constitucional, aquí nos centraremos solo en el origen y en las distintas opciones que hay dentro de los grandes sistemas de control de constitucionalidad de la ley.

En la actualidad, **algunos países han optado por un control de constitucionalidad de las leyes por uno o varios órganos políticos y otros por un control jurisdiccional:**

- **Si el control es eminentemente político** también hay distintas variantes, porque **este control se puede encargar a varios tipos de órganos**, como por ejemplo un órgano específicamente creado para esta función (como es el caso francés) o una comisión del Parlamento (como ocurre en algunos países nórdicos), o puede ser una prerrogativa del jefe del Estado aunque compartida con otros órganos (como por ejemplo en Grecia, Perú, Bulgaria, Argentina o Polonia, entre otros, que ponen a disposición del jefe del Estado la posibilidad de vetar la aprobación de una norma para evitar una contradicción constitucional).
- **Dentro del sistema jurisdiccional también hay varias opciones**, porque **el control puede estar concentrado en manos de un solo órgano** (tribunal constitucional), como Alemania, Italia o España, **o ser un control difuso** (ejercido por todos los integrantes del poder judicial), como en Estados Unidos, Canadá o Australia. **E incluso puede haber sistemas como los mixtos** (que nacen de una fusión o mixtura de otros sistemas, como sería el caso de Brasil) **y los duales o paralelos** (en expresión de García Belaunde), en los que el control de constitucionalidad de las leyes ha sido encargado simultáneamente a la jurisdicción ordinaria y a un tribunal constitucional; es lo que ocurre en países como por ejemplo Perú, Portugal o Grecia (país que ha optado por un Tribunal Supremo Especial que tiene una característica que lo hace bastante singular, porque no es un órgano permanente, sino temporal, de modo que se constituye cada vez que aparece un asunto del que es competente y se disuelve después de resolverlo).

Es importante, pues, tener presente desde un inicio que **hay muchas fórmulas para efectuar el control de constitucionalidad de las leyes, y que son fórmulas que se influyen de manera recíproca y evolucionan.**

Es interesante ver cómo los procesos de integración supranacionales han desembocado en cambios también en este ámbito del control de constitucionalidad de las leyes. Así, por ejemplo, el hecho de que el Reino Unido sea parte del Consejo de Europa y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda dictaminar sobre la conformidad de las normas británicas con el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha motivado que se establezca un control dentro del Reino Unido para que este país pueda soberanamente determinar la conformidad y evitar que solo desde Estrasburgo se tomen estas decisiones. Finlandia también es un ejemplo, fruto ahora, sin embargo, de la integración dentro de la Unión Europea, de establecimiento de control jurisdiccional en un sistema donde había hasta hace poco solo un control político.

Sin embargo, a pesar de **la gran diversidad de opciones para efectuar el control de constitucionalidad de las leyes**, las muy numerosas fórmulas que hoy día hay se **pueden agrupar en tres grandes familias o modelos originarios y dos modelos más derivados**. La distinción entre control jurisdiccional concentrado en un solo órgano o difuso en todos los tribunales ordinarios es la característica básica que distingue entre el sistema norteamericano (control

difuso) y el sistema europeo (control concentrado). A estos dos sistemas de control jurisdiccional, hay que añadir un tercer modelo no jurisdiccional: el de control político, como por ejemplo el sistema francés confiado en un solo órgano. Estos tres modelos se pueden denominar *originarios*, porque surgen independientemente los unos de los otros, sin mucho contacto ni influencias recíprocas; ahora bien, con el tiempo los modelos dejan su pureza originaria y se influyen mutuamente. Junto a estos tres modelos originarios, hay otros que podemos denominar derivados, porque son fruto o consecuencia de los anteriores; surgen para dar respuesta a necesidades concretas en diferentes países y si lo consiguen es donde se han consolidado. Dentro de los sistemas derivados, situaríamos dos tipos: el mixto (que nace fruto de una mixtura o fusión de otros sistemas, como por ejemplo el de Brasil) y el dual o paralelo, que es un sistema en el que no hay fusión o mezcla, sino que engloba dos o más modelos, que coexisten sin interferencias, como sería el caso de la Constitución de Perú.

4.3.1. El sistema norteamericano o modelo difuso de justicia constitucional

La justicia constitucional surge históricamente en EE. UU. a partir de la sentencia del Tribunal Supremo *Marbury vs. Madison* (1803), cuando este tribunal estaba presidido por el juez John Marshall. **No es la constitución la que lo establece, sino la práctica judicial**, mediante la aplicación de la cláusula de supremacía de la constitución ubicada en el art. VI del texto constitucional. A partir de aquí, y según el *stare decisis* (precedente vinculante u obligatorio), que es uno de los fundamentos del sistema jurídico y judicial de Estados Unidos, magistrados como Josep Story u Oliver Wendell Holmes, entre otros, irán desarrollando con más amplitud y sistematicidad el *judicial review* o *control difuso de la constitucionalidad de las leyes*.



Sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América.

El sistema norteamericano se caracteriza por el hecho de que **todos los jueces y magistrados pueden ejercer el control de constitucionalidad de las leyes**; no hay un tribunal creado *ad hoc* (específicamente) para llevar a cabo este control. Son las partes en un proceso judicial las que piden el examen de la constitucionalidad de la ley. **Se trata de un control incidental**: en el decurso de un proceso principal, alguna de las partes discute la constitucionalidad de la ley que el juez tiene que aplicar, incidente que **es resuelto por el mismo juez**. Por lo tanto, este **inaplica la ley** en el caso concreto (no es un control abstracto de la ley). Así, es posible que otro juez llegue a una conclusión diferente si tiene que aplicar la misma ley. Dado que **los efectos de la decisión son para el caso concreto** (*inter partes*), **no suponen la anulación general**. Por el hecho de que la verificación de la constitucionalidad de una ley la lleva a cabo un juez que tiene evidentemente una legitimidad democrática mucho menos directa que la del Parlamento que ha aprobado la ley, en este sistema los jueces pueden «inaplicar» una ley que consideren que es inconstitucional, pero no la pueden «expulsar» del ordenamiento jurídico. Ahora bien, ante una peligrosa dispersión de decisiones judiciales, que podrían ser contradictorias,

hay dos mecanismos que dan una cierta unidad al sistema de control y seguridad jurídica: el principio del *stare decisis*, mediante el cual los jueces quedan vinculados al precedente, y la existencia de una instancia suprema y unificadora que es el Tribunal Supremo, cuyas decisiones tienen que ser aceptadas por todos los órganos judiciales inferiores. Aun así, y para acabar de equilibrar el sistema, los tribunales y especialmente el TS habitualmente procuran evitar lo máximo posible las cuestiones propiamente políticas y, por lo tanto, también reducen los casos de interpretación constitucional en los que lo que se plantea es un elemento claramente político (*self-restraint*).

4.3.2. El sistema europeo o modelo concentrado de justicia constitucional

El sistema europeo (también denominado austríaco o kelseniano) se desarrolla posteriormente, una vez entrado el siglo xx, después de la Primera Guerra Mundial, principalmente gracias a Hans Kelsen⁴. Las primeras concreciones fueron prácticamente simultáneas en Checoslovaquia (febrero de 1920) y Austria (octubre de 1920), y poco tiempo después en la Constitución de la Segunda República Española (1931).

Sin embargo, en Checoslovaquia prácticamente no funcionó (emitió una sola sentencia antes de ser disuelto) y el Tribunal de Garantías constitucionales español que se constituyó en 1933 fue abortado por el golpe de estado franquista de 1936. En cambio, el Tribunal Constitucional austríaco resurgió después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando este país retomó su Constitución de 1920 y sus instituciones democráticas, y funciona desde entonces. De aquí su importancia no solo teórica, sino también histórica y práctica, que los otros dos no tienen.

⁽⁴⁾Hans Kelsen (1881-1973) recibió el encargo de diseñar la que finalmente fue la constitución austríaca de 1920, pero no es técnicamente la que contiene el primer tribunal constitucional. La Constitución de Checoslovaquia, también de 1920, la precedió algunos meses y se ocupó del control concentrado de la constitucionalidad según las líneas maestras trazadas por Kelsen.

En el sistema concentrado, el tribunal constitucional, que puede formar parte del poder judicial –como Alemania– o no formar parte del mismo (como es el caso español), **tendrá el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes**. Este control se hará **en un proceso autónomo y específico, de manera abstracta**, con independencia de la aplicación práctica de la ley. Solo pueden acceder al mismo determinados sujetos, órganos políticos (jefe de Estado, Gobierno, Parlamento), y **los efectos de la decisión son *erga omnes***, es decir, generales, dado que **comportan la nulidad** de los preceptos declarados inconstitucionales. El tribunal constitucional se configura como «legislador negativo», porque la nulidad de los preceptos declarados inconstitucionales supone la expulsión del ordenamiento jurídico (pues nunca habrían tenido que formar parte del mismo, ya que no se pueden considerar normas válidas). Este sistema fue complementado a partir de la reforma de la Constitución austríaca en 1929, con la posibilidad de que los jueces instaran el control de constitucionalidad, en una vía indirecta, que se incorporó al modelo inicial en las constituciones más importantes aprobadas en la segunda posguerra, en Alemania y en Italia, que son aquellas en las que más se inspiró la Constitución española de 1978.

4.3.3. El sistema francés o modelo de control político

El modelo francés es uno de los más relevantes entre los que optan por un control de constitucionalidad de la ley no jurisdiccional, sino político. Este sistema de control político nace y se desarrolla con las primeras constituciones francesas (1799 y 1852), después se afirma durante el siglo XIX y reaparece en varios países de América del Sur por ejemplo y, de manera destacada, en la Constitución estalinista de 1936, que tendrá gran influencia en las constituciones que se inspiraron en la soviética.

El sistema francés actual **confía este control en exclusiva a un órgano político**, el Consejo Constitucional (Conseil Constitutionnel), creado por la Constitución de 1958 (Título VII, arts. 56 a 63); son miembros del mismo con carácter vitalicio los expresidentes de la República y nueve miembros más con un mandato de nueve años y elegidos por los presidentes de la República, de la Asamblea Nacional y del Senado (cada uno de ellos elige a tres). Pese a su composición marcadamente política, hoy día emite dictámenes de contenido y estructura propios de una sentencia. El Consejo Constitucional **actúa** al final del procedimiento legislativo y **justo antes de la entrada en vigor de la norma**, de modo que se evita la introducción de normas inconstitucionales en el ordenamiento jurídico. Se pronuncia a instancia de otros órganos del Estado, característica que comparte con los otros dos grandes modelos (el norteamericano y el europeo). Se trata de un sistema basado en la rígida aplicación de la división de poderes y de extrema desconfianza hacia los jueces, a los cuales prohíbe formalmente enjuiciar la constitucionalidad de las leyes.

Este esquema inicial se tiene que complementar con el que implicó la reforma constitucional del 2008, que confiere al Consejo Constitucional, entre otras facultades, la de ejercer el control de constitucionalidad con ocasión de la aplicación de la ley en litigios concretos para contravenir derechos y libertades constitucionales, es decir, se otorga por primera vez (a pesar de que se habían producido anteriores intentos fallidos) un control de la ley *a posteriori*, con la posibilidad de abrogar la disposición declarada inconstitucional y con posibilidades de modular los efectos temporales con amplio margen de disposición de los efectos de sus decisiones, que lo acerca con más intensidad a la concepción tradicional de los tribunales constitucionales.

Estos tres modelos, que inicialmente son contrapuestos (jurisdiccional/político, y entre los dos jurisdiccionales, uno difuso, incidental y con control concreto, y el otro concentrado, directo y con control abstracto) han evolucionado hacia una cierta convergencia, especialmente los de control jurisdiccional; así, para Manuel Aragón, si actualmente hay **un rasgo que puede caracterizar la expansión de la justicia constitucional es, sin duda, la «relativización» de las diferencias entre los modelos originarios de control de constitucionalidad.**

Así, por ejemplo, en el modelo de Estados Unidos el principio del *stare decisis* para muchos autores ha significado que el Tribunal Supremo cada vez se asemeje más a un auténtico tribunal constitucional (aunque no tenga este nombre ni tampoco se encuentre fuera del poder judicial); por su parte, la aproximación del modelo europeo o concentrado al sistema difuso norteamericano ya empezó con la reforma de la Constitución austríaca de

1929 que, como ya se ha apuntado, estableció un control por vía incidental al permitir que los tribunales supremos en materia civil, penal y administrativa pudieran plantear ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de una ley y, por lo tanto, un precepto situado en un determinado contexto y aplicado a un caso concreto (de este modo, se extendía la *competencia de comprobación* de la compatibilidad de las leyes con la Constitución, pero se mantenía la *competencia de rechazo* concentrada en el TC). También se puede observar esta confluencia cuando algunos tribunales constitucionales, por medio del procedimiento de amparo de derechos fundamentales, llegan a juzgar la constitucionalidad de una ley porque consideran que es la que vulnera un derecho fundamental, porque juzgan de manera parecida a como lo hacen los jueces de la jurisdicción ordinaria, valorando los hechos y, por lo tanto, llevando a cabo un control concreto de la norma. Además, si el recurso de amparo accionado por un recurrente puede acabar sirviendo indirectamente para juzgar la constitucionalidad de una ley, esto también acerca en cierta medida este sistema al control difuso que está en manos de cualquier parte de un juicio.

También hay que tener presente que ha evolucionado el postulado kelseniano que limitaría el papel del TC a una función de legislador negativo, porque algunos tribunales constitucionales llevan a cabo una función cercana a la de un legislador positivo (Rubio Llorente) cuando innovan contenidos interpretativos de la ley con las denominadas sentencias interpretativas, cuando transforman el sentido de un precepto por medio de las sentencias manipulativas, o bien ejercen labores paralegislativas, como sucede en las sentencias aditivas (el tribunal añade un precepto al declarar la inconstitucionalidad de una omisión del legislador).

Por otro lado, hay algunos países en los que la concreción de su justicia constitucional es difícil de asignar a uno u otro modelo, porque presentan algunos elementos o características de otro sistema al que teóricamente pertenecen, y no solo los países que han adoptado un sistema mixto (como Brasil) o dual o paralelo (como Perú). Por lo tanto, a pesar de que pueda resultar útil para una mejor conceptualización mantener esta clasificación en tres grandes sistemas originarios y dos más derivados, hay que tener presente que las opciones concretas que han adoptado las constituciones hoy en día son muy variadas, fruto de una decisión del poder constituyente que, como veremos en el módulo 3, es de las más importantes que tiene que tomar (junto con la decisión sobre la forma de Estado, la forma de Gobierno o la organización territorial).

¿Cómo eligen los constituyentes la fórmula de su justicia constitucional? En general, hay varios factores que tienen incidencia, pero a menudo la influencia de otros países, y sobre todo su pasado político (que supone una cultura política y jurídica), son los factores más relevantes.

Así, por ejemplo, en buena parte de los países latinoamericanos se adoptó inicialmente un control político (que encargaba al Parlamento la salvaguarda de la constitución) porque se inspiraron en algunas constituciones francesas (del periodo revolucionario y del posterior) y en la Constitución española de 1812, cuando se independizaron del imperio español, en lucha con Francia; un control político que también adoptaron países del este de Europa por influencia soviética. O, más recientemente, en Sudáfrica, por ejemplo, confluyó una fuerte influencia anglosajona con la del derecho continental traído por los bóeres, que generó un sistema normativo con elementos propios de la *common law* y del sistema europeo continental, y que instauró un tribunal constitucional muy activo y de gran trascendencia en el proceso de transición hacia la democracia.

Sin embargo, el elemento más relevante suele ser la tradición jurídica y la cultura política; así, por ejemplo, como señalan Fossas y Pérez Francesch, el sistema norteamericano de control de constitucionalidad de las leyes se tiene que entender en el contexto de las concepciones políticas y jurídicas propias de aquel país, y a partir de las ideas norteamericanas sobre la constitución, la soberanía, la ley y la división de poderes se puede llegar a entender la posibilidad de que los jueces ordinarios puedan fiscalizar la ley, entendida como decisión de los representantes del pueblo; y también a partir de una determinada

concepción del derecho, vinculada al sistema jurídico de la *common law*, se tiene que comprender el valor de las decisiones judiciales (*case law*) frente a las normas abstractas (*civil law*).

Por otro lado, la confianza o desconfianza hacia el poder legislativo o el judicial es un factor relevante en algunos estados. Así, algunos países escandinavos tienen un control de constitucionalidad en sede parlamentaria, entre otros motivos, porque en estos países hay una fuerte confianza en el poder legislativo (se confía en que el Parlamento no legislará para romper el orden constitucional), mientras que en la base del sistema de control político de Francia (que actualmente monopoliza el Consejo Constitucional) lo que hay es una tradición de desconfianza hacia los jueces. En Francia, este recelo arranca con la revolución de 1789, cuando los jueces y magistrados en buena parte provenían de la aristocracia (no hay esta desconfianza hacia el legislador porque fue un poder conquistado por la burguesía); esta desconfianza hacia el juez fue propagada por ilustrados como Montesquieu, que consideraban que el juez solo podía ser *la bouche de la loi* (la boca de la ley), haciendo referencia al hecho de que tenían que ceñirse a la interpretación de lo que decía el texto de la ley.

En cambio, el sistema jurisdiccional concentrado, que surge en el periodo de entreguerras, se extiende por Europa después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones, para procurar que no se repitieran aquellos regímenes totalitarios vencidos, buscando mecanismos jurídicos que fortaleciesen el Estado de derecho y la democracia e intentando que el poder político estuviera sometido a un sistema de control establecido constitucionalmente (con un tribunal constitucional *guardián* de la carta fundamental ante los actos del legislador); y así el tribunal italiano emerge después de la caída del régimen fascista de Mussolini, y el tribunal alemán se instala en un contexto de rechazo al nazismo, y lo mismo pasó después del franquismo con la Constitución española de 1978, en la que a pesar de que la confianza inicial con el poder judicial era mínima, la entrada en vigor de la Constitución no supuso la destitución de ningún juez ni magistrado, cuando todos se habían formado profesionalmente en el franquismo y habían colaborado con el mismo como funcionarios.

4.4. La interpretación de la constitución y del ordenamiento jurídico conforme a la constitución

La interpretación de una norma jurídica es la actividad que tiene como resultado la determinación del contenido de la norma. El objetivo de la interpretación es lograr el enunciado preciso de la norma jurídica. Para poder ser aplicadas, todas las normas jurídicas tienen que ser interpretadas por los operadores jurídicos (como por ejemplo los particulares, abogados, funcionarios o jueces). Las constituciones, también. **Todos los criterios interpretativos habituales para determinar el contenido de las normas pueden y tienen que ser aplicados para interpretar las constituciones** (criterio gramatical, sistemático, histórico, teleológico y sociológico); **la diferencia se tiene que encontrar en el carácter de la constitución, que es una norma cualitativamente diferente de las otras normas del ordenamiento jurídico. Una diferencia importante entre una constitución y el resto de las normas está en el más alto grado de generalidad y abstracción que generalmente caracterizan la constitución.** Así, por ejemplo, **la vaguedad semántica es una característica de la Constitución española de 1978.**

La misma naturaleza de constitución supone que una gran parte de sus preceptos tengan una estructura principal. **A la hora de interpretar una constitución, hay que tener en cuenta que habitualmente tiene una estructura normativa interna compleja**, es decir, está integrada por normas concretas que pueden ser aplicadas directamente por un juez, pero también por pre-



Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) fue un jurista alemán, de la escuela histórica de derecho alemana. En su *Sistema del Derecho Romano actual*, estructuró dogmáticamente los criterios de interpretación utilizados por los jueces al aplicar las leyes en cuatro grandes elementos (gramatical, lógico, histórico y sistemático), y sus categorías teóricas llegaron a ser una de las bases de la dogmática jurídica moderna.

ceptos muy abiertos, muy principales. Normalmente, las constituciones configuran el legislativo como un poder libre, que no ejecuta el texto constitucional, sino que actúa con libertad dentro de los límites establecidos por la constitución. La interpretación constitucional tiene que partir del hecho de que corresponde al legislador la libre determinación de las leyes, que no están regidas por la necesidad de completar o desarrollar la constitución, sino por el imperativo de no contradecirla (Ignacio de Otto).

El método de interpretación de la constitución parte de un supuesto diferente del método de interpretación de las otras normas jurídicas. No se trata tanto de llegar a un contenido unívoco y concreto de la norma constitucional, sino simplemente de excluir las interpretaciones de las normas que le sean contrarias. El razonamiento jurídico es, por lo tanto, diferente (Javier Pérez Royo).

Así, el objetivo de la interpretación constitucional es definir el marco dentro del cual se expresa válidamente el pluralismo, para permitir que una sociedad cambiante, por medio de mayorías políticas, determine los contenidos de la constitución, que no son ni unívocos ni estáticos.

La jurisprudencia constitucional lleva a cabo una importante tarea interpretativa de la constitución y de las leyes. **El tribunal constitucional** (en los estados con un sistema concentrado de justicia constitucional) **o el tribunal supremo** (en los países con un sistema difuso) **son el intérprete supremo de la constitución**, a pesar de que no el único. Las declaraciones interpretativas mediante sus sentencias tienen un gran valor, porque se imponen al resto de los poderes, empezando por el poder judicial ordinario.

Finalmente, a la hora de interpretar una constitución, hay que tener presente que **la finalidad de la interpretación jurídica consiste en averiguar el sentido de la norma, no el propósito consciente del autor**: una vez nacida, la norma adquiere vida propia y se convierte en independiente de su autor (Isidre Molas). Por lo tanto, **se trata de interpretar la voluntad de la constitución y no la voluntad del constituyente** (que a menudo es difícil de establecer porque es una obra colectiva). **Aun así, a menudo la voluntad y los motivos del constituyente se recogen en el preámbulo** de las constituciones y son un argumento interpretativo (argumento psicológico) **y pueden proporcionar criterios importantes para los argumentos teleológico o histórico**. Las corrientes doctrinales originalistas, en la medida en que subrayan el carácter de la constitución como pacto, otorgan un gran valor al poder constituyente y, por lo tanto, a la intención de este poder originario a la hora de redactar la norma constitucional. Ahora bien, el respeto a la literalidad y a una versión originalista tiene que ser matizado por el reconocimiento de la coincidencia



Un claro exponente del originalismo en la interpretación de la Constitución de Estados Unidos fue el juez del Tribunal Supremo de aquel país, Antonin Scalia (1936-2016).

de una pluralidad de voluntades y por la atención de que la constitución es una realidad viva en su comprensión y aplicación y, por lo tanto, sujeta a evolución.

Por otro lado, de la supremacía normativa de la constitución se deriva el principio de que **todo el ordenamiento tiene que ser interpretado conforme a la constitución**. Este principio supone que las leyes y los reglamentos tienen que ser considerados constitucionales siempre que una de las interpretaciones posibles pueda ser considerada conforme a la constitución.

Por lo tanto, los jueces, en el momento de interpretar las leyes, tienen que hacer **un juicio de adecuación constitucional**: deben buscar una interpretación de la ley que sea conforme a la constitución. Si no encuentran ni una sola interpretación de la ley compatible con la constitución, tienen que inaplicar la ley al caso concreto (en el sistema de control difuso) o deben preguntar al tribunal constitucional para que sea este quien decida (en el sistema europeo o de control concentrado). En este último sistema, hay dos posibilidades: si el tribunal constitucional encuentra una interpretación posible de la ley que no contradiga la constitución, la ley continuará siendo válida (principio de conservación de la norma, basado en el principio democrático –el pueblo elige al legislador y no a los jueces–), y el juez ordinario la aplicará; pero si el tribunal constitucional no encuentra ni una sola interpretación de la ley que sea compatible con la constitución, la declarará inválida y aquella norma se tiene que expulsar del ordenamiento jurídico.

La interpretación de las normas conforme a la constitución es un reflejo de la supremacía constitucional dentro del ordenamiento jurídico. De hecho, es la base del sistema; sirve para cerrar el modelo.

Finalmente, hay que mencionar las **mutaciones constitucionales**, que son **cambios en el sentido del texto de la constitución sin que esta se modifique formalmente**. Estas modificaciones se producen por la práctica política o el funcionamiento real de los poderes públicos, por distintas vías, como por ejemplo la práctica jurisprudencial, por costumbres, por convenciones o acuerdos.

Hay muchos tipos de mutaciones: prácticas que no están previstas en la constitución (el control de constitucionalidad de las leyes en Estados Unidos); prácticas opuestas a la constitución (el mandato imperativo que ejercen los partidos políticos sobre los representantes, por ejemplo, en el caso español); el desuso de determinadas competencias (el derecho de veto del rey en determinadas monarquías parlamentarias, como Inglaterra); cambio de sentido de los preceptos constitucionales (como la cláusula de comercio en Estados Unidos, que la jurisprudencia ha considerado siempre de competencia de la federación, o el art. 32.1 de la Constitución española, que donde decía que el hombre y la

mujer tienen derecho a contraer matrimonio se ha entendido como el derecho de dos personas a contraer matrimonio); o acuerdos sobre prácticas políticas no previstas en la constitución (en la Constitución italiana, se considera que el voto negativo del Parlamento al proyecto de Ley de presupuestos equivale a una moción de censura). En todos estos casos, se trata de procesos interpretativos del texto constitucional que persiguen la adaptación a las nuevas circunstancias sin tener que recurrir a la reforma formal de la constitución.

Resumen

En este módulo, se ha estudiado el origen y la evolución del Estado, como instrumento de poder soberano sobre un pueblo y en un territorio. Así, en un sentido amplio, hemos definido el Estado como grupo social jurídicamente organizado y formado por una comunidad estable de personas, asentada en un territorio y dotada de un poder soberano. También se ha analizado el concepto de constitución y de constitucionalismo, destacando las teorizaciones y procesos revolucionarios que dieron como consecuencia la aparición de un Estado nuevo, opuesto en su dinámica y estructura al Estado absolutista, el Estado constitucional, derivado de procesos revolucionarios como por ejemplo las revoluciones inglesas de finales del siglo XVII, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789. Desde entonces, se consagró un nuevo instrumento de limitación del poder que se denominará constitución; un texto articulado en el que se plasmarán los principios básicos del liberalismo, como la división de poderes y la proclamación de los derechos del ciudadano. Sin embargo, el constitucionalismo original, derivado de los mencionados procesos revolucionarios, está muy lejos de asemejarse al constitucionalismo que sirve de base a los actuales estados, más evolucionados en aspectos como por ejemplo la garantía de los derechos de las personas, la regulación en derecho de los procesos políticos, el sufragio universal o el control de constitucionalidad de las leyes. El siglo XX supondrá el paso del constitucionalismo liberal al constitucionalismo democrático, con importantes avances después de las dos guerras mundiales. A partir de entonces, se dio también una extensión del constitucionalismo propiciada por el proceso de descolonización.

También se ha analizado el concepto normativo de constitución, la materia propia de las constituciones y sus funciones, la elaboración y reforma de los textos constitucionales, con referencia al poder constituyente y el poder de reforma, y se ha explicado la importancia de la justicia constitucional, como instrumento de garantía del carácter normativo y supremo de la constitución, atribuido a los tribunales ordinarios (sistema difuso) o a un tribunal *ad hoc*, el tribunal constitucional (sistema concentrado) o a un órgano político (como en el caso francés).

Para acabar, se ha explicado que todos los criterios interpretativos habituales para determinar el contenido de las normas pueden y tienen que ser aplicados para interpretar las constituciones; sin embargo, una diferencia importante entre una constitución y el resto de las normas del ordenamiento jurídico reside en el más alto grado de generalidad y abstracción que en general caracteriza a la constitución. Otra diferencia que hay que tener en cuenta es que el método de interpretación de la constitución parte de un supuesto diferente del método de interpretación de las otras normas jurídicas. No se trata tanto de llegar a un contenido unívoco y concreto de la norma constitucional, sino

simplemente de excluir las interpretaciones de las normas que le sean contrarias. En consecuencia con la supremacía normativa de la constitución, hemos visto que todo el ordenamiento tiene que ser interpretado conforme a ella, y este principio implica que las leyes y los reglamentos tienen que ser considerados constitucionales siempre que una de las interpretaciones posibles pueda ser considerada conforme a la constitución. También hemos destacado el importante papel de la jurisprudencia constitucional en la configuración del derecho constitucional y su carácter de interpretación suprema, que no quiere decir única, del texto constitucional.

Actividades

1. Argumentad por qué la afirmación siguiente se puede considerar válida hoy día o ya no: «El Estado se caracteriza por tener unos órganos despersonalizados, una Administración propia, unas fronteras determinadas, unas leyes que se aplican a un ámbito territorial, un ejército permanente (o una política de defensa) y una hacienda propia y una política de aranceles».
2. Buscad y leed la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América (4 de julio de 1776) e identificad en ella los fundamentos ideológicos del constitucionalismo que tenéis explicados en el presente módulo didáctico.
3. Argumentad a favor o en contra de la afirmación siguiente: la ruptura jurídica de un sistema político no se puede considerar positiva o negativa, sino que dependerá de cuál sea el régimen del que se parte y el que se cree de nuevo, y de la forma en que se haga la transición.
4. Exponed elementos a favor y en contra de la existencia de «cláusulas de intangibilidad» en las constituciones.
5. Exponed ventajas e inconvenientes de la rigidez constitucional, y argumentad cuál podría ser la justificación que hace que la voluntad de la generación presente (expresada en las leyes del Parlamento democráticamente elegido) tenga que estar vinculada a decisiones políticas tomadas por generaciones del pasado. ¿Por qué la voluntad de la generación pasada tiene que prevalecer sobre la actual? ¿Por qué una constitución aprobada en el pasado se tiene que imponer a un Parlamento elegido democráticamente hoy?
6. Exponed las diferencias entre los conceptos de constitución-proceso y de constitución-programa o dirigente. Poned algunos ejemplos tomados de la Constitución española de 1978.
7. Analizad las funciones de «legislador positivo» y de «legislador negativo» a la hora de interpretar la constitución.
8. Exponed las principales diferencias y similitudes entre el modelo concentrado y el difuso de justicia constitucional.

Ejercicios de autoevaluación

1. Según Loewenstein, las constituciones que son observadas y aplicadas se denominan...
 - a) Semánticas.
 - b) Nominales.
 - c) Normativas.
 - d) Rígidas.
2. La formación y consolidación del Estado moderno fueron paralelas...
 - a) A la institucionalización del poder bajo la forma de monarquías absolutas.
 - b) A la configuración del poder bajo repúblicas satélites.
 - c) Al feudalismo.
 - d) A la desaparición de las monarquías absolutas.
3. ¿A qué hace referencia el concepto de constitución flexible o rígida?
 - a) A si son producto de un proceso revolucionario.
 - b) Las rígidas son producto del antiguo régimen, y las flexibles, de la Revolución Francesa.
 - c) A si se trata de una monarquía o una república.
 - d) A la facilidad mayor o menor de su revisión o reforma.
4. Las cartas otorgadas, frecuentes en el siglo XIX, fueron...
 - a) Producto de un acto formalmente voluntario del rey, mediante el cual se autolimitaba los poderes.
 - b) Producto de un pacto entre el rey y el Parlamento, para garantizar la supremacía de este último.
 - c) Producto de un pacto entre el rey y el parlamento, que asegurase la supremacía del primero.
 - d) Constituciones democráticas que el pueblo se otorga a sí mismo.

5. Todo sistema constitucional implica, en rigor,...

- a) Un régimen de limitación del poder político consagrado en un único texto.
- b) La división de los poderes públicos y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
- c) La libertad absoluta de los ciudadanos como cuerpo electoral.
- d) El dominio de la mayoría sobre la minoría de manera jurídicamente incondicionada, pero políticamente responsable.

6. El control de constitucionalidad de las leyes...

- a) Se inició con las constituciones estamentales.
- b) Fue ideado principalmente por Kelsen.
- c) Se inspiró en la división de poderes de Locke.
- d) Se inició en Estados Unidos de América.

7. Son fundamentos teóricos del constitucionalismo:

- a) El absolutismo, el contractualismo, el racionalismo.
- b) El contractualismo, el racionalismo, el liberalismo.
- c) El racionalismo, el legalismo, el principio de dependencia normativa.
- d) El contractualismo, el racionalismo, el marxismo.

8. Liberalismo y democracia son conceptos...

- a) Sinónimos.
- b) Excluyentes.
- c) Diferentes.
- d) Relativos.

9. La idea de constitución en sentido material...

- a) Parte del supuesto de que lo que define las normas constitucionales es su contenido.
- b) Se identifica con la constitución formal.
- c) No añade nada al concepto de constitución.
- d) Coincide plenamente con el texto de la constitución.

10. En un sistema de control difuso, la constitucionalidad de las leyes se atribuye...

- a) Al tribunal constitucional.
- b) A los jueces y tribunales ordinarios del país.
- c) A los magistrados del Tribunal Penal Internacional.
- d) Al Consejo General del Poder Judicial.

11. En un gran número de textos constitucionales, se puede distinguir...

- a) Una parte traslativa del poder y una segunda más funcional.
- b) Preceptos ordenados y otros traslativos.
- c) Una parte organizativa y otra semántica.
- d) Una parte orgánica y otra dogmática.

12. Además del ordenamiento jurídico, ¿cuáles son los elementos constitutivos del Estado?

- a) Nación, pueblo y Gobierno.
- b) Territorio, pueblo y poder soberano.
- c) Nación, pueblo y municipio.
- d) Poder soberano, nación y población.

13. La interpretación de la constitución...

- a) Solo la puede llevar a cabo el tribunal constitucional o el tribunal supremo, según si es un país de control concentrado o difuso de la constitucionalidad de las leyes.

- b) La tiene que hacer cualquier operador jurídico que la aplique.
- c) Solo se puede hacer de acuerdo con un criterio literal y originalista.
- d) No es posible porque se tiene que aplicar sin interpretar.

14. Las mutaciones constitucionales...

- a) Son reformas de la constitución hechas siguiendo el procedimiento previsto en la misma constitución.
- b) Son cambios en el sentido del texto de la constitución, sin que esta se modifique formalmente.
- c) No existen en los sistemas democráticos actuales.
- d) Son lo mismo que las denominadas cláusulas de intangibilidad.

Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1. c
2. a
3. d
4. a
5. b
6. d
7. b
8. c
9. a
10. b
11. d
12. b
13. b
14. b

Glosario

CE *f* Constitución española de 1978.

constitución *f* Texto jurídico formado por las normas jurídicas supremas del Estado, relativas a la organización del poder político y a la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

constitucionalismo *m* Movimiento ideológico y político que nace vinculado a los principios liberales y que llega hasta nuestros días incorporando la filosofía democrática, lo que supone la elaboración de textos constitucionales.

elementos constitutivos del Estado *m pl* Según la doctrina, son aquellos sin los cuales teóricamente el Estado no puede existir o no tiene sentido: el ordenamiento jurídico, el poder soberano, el pueblo y el territorio.

Estado *m* Forma de organización política que se desarrolla en Europa desde el Renacimiento hasta nuestros días, y que ha llegado a ser la principal forma de organización política contemporánea. Es la forma de organización política en la que un grupo social se organiza jurídicamente, se asienta en un territorio y se dota de unas instituciones de gobierno con un poder soberano, que reivindica con éxito un doble monopolio, el de la coacción física legítima y del reconocimiento del derecho.

Estado liberal *m* Forma de Estado que se implantó a raíz de las revoluciones liberales, caracterizado por la distinción y la no confusión entre Estado y sociedad, entre el ámbito del poder y el de la libertad. El Estado tenía que abstenerse de intervenir en la vida social y económica de las personas. Su criterio inspirador fue la garantía de la libertad individual, por lo cual se desarrolló el constitucionalismo y se aprobaron textos constitucionales que organizaron el Estado según la separación de los poderes y la protección de los derechos fundamentales.

interpretación constitucional *f* Mecanismo mediante el cual los operadores jurídicos buscan, después de argumentación, el sentido de las expresiones contenidas en las normas y principios constitucionales. Como parte de la interpretación jurídica, se pueden aplicar varios criterios (textual, finalista, originalista, etc.).

jurisprudencia *f* Doctrina que se desprende de las *ratio decidendi* de reiteradas sentencias de los tribunales de última instancia sobre una misma materia y un mismo supuesto.

justicia constitucional *f* Es un instrumento de garantía del carácter normativo y supremo de la constitución, atribuido a los tribunales ordinarios (sistema difuso) o a un tribunal *ad hoc*, el tribunal constitucional (sistema concentrado), o un órgano político (como en el caso francés).

LRP *f* Ley para la reforma política de 1976, última de las leyes fundamentales del franquismo, que permitió la transición política y las elecciones de 15 de junio de 1977, de las cuales surgieron las Cortes, que, *de facto*, llegaron a ser constituyentes.

materia constitucional *f* Contenido propio de las constituciones, en el que hay necesariamente la delimitación del ejercicio del poder político mediante el principio de la separación de poderes y la garantía de los derechos y libertades de las personas. A este contenido «irrenunciable» se puede añadir la existencia de principios definitorios del sistema político instaurado y las cláusulas de la reforma constitucional.

ordenamiento jurídico estatal *m* Conjunto ordenado, coherente y completo de las normas jurídicas válidas y vigentes en un Estado, que constituye, regula y expresa el Estado.

parte dogmática de la constitución *f* Parte relativa a la garantía de los derechos y libertades, y al establecimiento de los principios políticos que inspiran la vida política y social.

parte orgánica de la constitución *f* Parte del texto constitucional relativa a la organización y el funcionamiento de los poderes constituidos del Estado.

poder constituyente *m* Poder teóricamente originario, ilimitado, prejurídico y único que efectivamente hace la constitución y delimita los poderes constituidos. Es el titular de la soberanía; desde la perspectiva democrática, el pueblo.

reforma de la constitución *f* Procedimiento establecido en la misma constitución, mediante el cual se puede proceder al cambio de una parte de su texto, siguiendo normalmente unas pautas más rígidas y difíciles que para la reforma de una ley cualquiera.

rigidez constitucional *f* Característica que tiene una constitución cuando no se puede reformar por el procedimiento legislativo ordinario.

ruptura constitucional *f* Cambio político que se produce sin seguir las previsiones constitucionales de reforma y, por lo tanto, se produce una solución de continuidad entre los dos regímenes sucesivos, con intervención del poder constituyente originario en la creación del segundo.

separación de poderes *f* Principio que inspira desde sus orígenes el Estado constitucional. Se trata de un principio según el cual hay que conseguir la limitación del poder del Estado, y con esta finalidad se entiende que el poder frena el poder. La formulación clásica es la separación entre ejecutivo, legislativo y judicial, en un sistema de equilibrios, frenos y contrapesos.

soberanía *f* Concepto que expresa el máximo poder que se puede ejercer jurídicamente, en el sentido de que no tiene otro por encima, tanto hacia el exterior (independencia) como hacia el interior de la comunidad política (supremacía). Atributo que se predica del Estado y que supone una reivindicación de la máxima capacidad de decisión en todos los órdenes de la vida pública.

STC *f* Sentencia del Tribunal Constitucional.

TC *m* Tribunal Constitucional.

tribunal constitucional *m* Órgano jurisdiccional que ejerce el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes, en los sistemas de justicia constitucional concentrada, como el Estado español.

Bibliografía

1) Sobre sistema político, sistema social y legitimidad

Bobbio, N. (2003). *Teoría general de la política*. Madrid: Editorial Trotta.

Bouza-Brey, L. (2005). «El poder y los sistemas políticos». En: Caminal Badia, M. (ed.). *Manual de ciencia política*. Madrid: Tecnos.

Duverger, M. (1988). *Instituciones políticas y derecho constitucional*. Barcelona: Ariel.

Hobbes, Th. (2009). *Leviatán*. Madrid: Alianza.

Nozick, R. (1988). *Anarquía, Estado y utopía*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Parsons, T. (1982). *El sistema social*. Madrid: Alianza editorial.

Rawls, J. (2010). *Una teoría de la justicia*. Barcelona: Accent editorial.

Rousseau, J. J. (1988). *El contrato social o principios de derecho político*. Madrid: Tecnos.

Weber, M. (2002). *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. Madrid: Fondo de Cultura de Cultura Económica.

2) Sobre el concepto y la evolución del Estado

Acosta Sánchez, J. (1989). *Teoría del Estado y fuentes de la Constitución*. Córdoba: Universidad de Córdoba.

Crossman, R. H. S. (1986). *Biografía del Estado moderno*. México: Fondo de Cultura Económica.

García Pelayo, M. (1985). *Las transformaciones del Estado contemporáneo*. Madrid: Alianza.

González Casanova, J. A. (1984). *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*. Barcelona: Vicens Vives.

Kriele, M. (1980). *Introducción a la teoría del Estado*. Buenos Aires: Depalma.

Molas, I. (2008). *Derecho constitucional*. Madrid: Tecnos.

Sabine, G. H. (1965). *Historia de la teoría política*. México: FCE.

Vallespín, F. (ed.) (1995). *Historia de la Teoría Política, 2*. Madrid: Alianza editorial.

3) Sobre la constitución y el constitucionalismo

Aragón Reyes, M. (coord.) (2001). *Temas básicos de derecho constitucional (vol. I)*. Madrid: Civitas.

Blanco Valdés, R. (2010). *La construcción de la libertad. Apuntes para una historia del constitucionalismo europeo*. Madrid: Alianza.

Dippel, H. (2009). *Constitucionalismo moderno*. Madrid: Marcial Pons.

Fioravanti, M. (2001). *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*. Madrid: Tecnos.

Fossas, E.; Pérez Francesch, J. L. (1994). *Lliçons de Dret Constitucional*. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

García de Enterría, E. (1981). *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*. Madrid: Civitas.

Jiménez Asensio, R. (2005). *El constitucionalismo. Proceso de formación y fundamentos del Derecho constitucional*. Madrid: Marcial Pons.

Loewenstein, K. (1983). *Teoría de la Constitución*. Barcelona: Ariel.

López Bofill, H. (2009). *Constitucionalisme a Catalunya. Preludi de modernitat*. Barcelona: Editorial Tria.

López Garrido, D. y otros (2017). *Derecho constitucional comparado*. Valencia: Tirant lo Blanch.

McIlwain, C. H. (1991). *Constitucionalismo antiguo y moderno*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Nieto, A. (1993). «Peculiaridades jurídicas de las normas constitucionales». En: *Revista de Administración Pública* (núms. 100-102).

Viver Pi-Sunyer, C. (1992). *Ordenament constitucional. Constitució*. Barcelona: Vicens Vives.

Wheare, K. C. (1975). *Las constituciones modernas*. Barcelona: Labor.

Zagrebezsky, G. (2011). *Historia y constitución*. Madrid: Trotta.

4) Sobre la constitución como norma jurídica suprema y su elaboración y reforma

Aláez Corral, B. (2000). *Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978*. Madrid: BOE-CEPC.

Aragón, M. (1990). *Constitución y democracia* (2.ª ed.). Madrid: Tecnos.

Blanco Valdés, R. L. (1994). *El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal*. Madrid: Alianza.

Castellà Andreu, J. M. (ed.) (2018). *Parlamento, ciudadanos y entes territoriales ante la reforma constitucional ¿Quién y cómo participa?* Valencia: Tirant lo Blanch.

De Vega, P. (1985). *La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente*. Madrid: Tecnos.

García De Enterría, E. (1985). «La Constitución como norma jurídica». En: *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*. Madrid: Civitas.

García Roca, J. (2017). «De la revisión de las constituciones: constituciones nuevas y viejas». En: *Teoría y Realidad Constitucional* (núm. 40, págs. 181-222).

López de Goicoechea Zabala, J.; Pascucci de Ponte, E. (coord.) (2018). *La reforma constitucional: propuestas y desafíos*. Pamplona: Aranzadi.

López Garrido, D. y otros (2017). *Derecho constitucional comparado*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Pérez Royo, J. (1987). *Reforma de la Constitución*. Madrid: Congreso de los Diputados.

Pérez Tremps, P. (2018). *Las reformas de la Constitución hechas y no hechas*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Pisarello, G. (2014). *Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática*. Madrid: Trotta.

Rubio Llorente, F. (1993). «La Constitución como fuente del Derecho». En: *La forma del poder*. Madrid: CEC.

5) Sobre la justicia constitucional

Abat i Ninet, A. (2010). *El Estatuto Jurídico de los Magistrados del Tribunal Constitucional Español. Estudio y análisis comparado*. Madrid: Aranzadi.

Ahumada Ruiz, M. (2005). *La jurisdicción constitucional en Europa*. Madrid: Civitas.

Ferreres Comella, V. (1997). *Justicia constitucional y democracia*. Madrid: CEPC.

Fernández Rodríguez, J. J. (2007). *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI*. Madrid: Tecnos.

Fernández Segado, F. (2013). *La evolución de la justicia constitucional*. Madrid: Dykinson.

García Belaunde, D. (2000). *De la jurisdicción constitucional al Derecho Procesal Constitucional*. Lima: Editora jurídica Grijley.

Kelsen, H. (1995). *¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?* Madrid: Tecnos.

Kelsen, H. (2016). *La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)*. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

López Garrido, D. y otros (2017). *Derecho constitucional comparado*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Pérez Tremps, P. (2010). *Sistema de justicia constitucional*. Madrid: Civitas.

Rubio Llorente, F. (1998). «Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa». En: F. Rubio Llorente y J. Jiménez Campo. *Estudios sobre jurisdicción constitucional* (págs. 155-173). Madrid: McGraw-Hill.

Schmitt, C. (1983). *La defensa de la Constitución*. Madrid: Tecnos.

Zabrebelsky, G. (2014). *La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia constitucional*. Madrid: Trotta.

